

Fondamentaux du contentieux. Maurin

APPRENDRE LES PROTOCOLES DE LA COUR EUROPEENNE

Il est utile de se familiariser avec le maniement des codes qui seront mentionnées tout au long du cours : Code de l'organisation judiciaire, code de procédure civile, code de justice administrative, code de procédure pénale...

Faire ISPEC SI DROIT PENAL

(MAURIN CONSEILLE : Le dictionnaire de la culture juridique de Stéphane Rials et, le dictionnaire des grandes œuvres juridiques pour **ENM 1 kilo de culture générale**, les corrigés de la prépa ISP, l'ENM met gratuitement en ligne toutes les annales avec les meilleures copies).

Plan :

INTRODUCTION

Chapitre préliminaire. Les principaux principes structurant la justice

- Section I. Le monopole de l'État
- Section II. L'indépendance des juridictions
- Section III. Le principe de collégialité
- Section IV. Le double degré de juridiction
- Section V. La publicité

PARTIE I – LES JURIDICTIONS EUROPÉENNES

Titre I. La Cour européenne des droits de l'homme

Chapitre I. L'organisation de la Cour européenne des droits de l'homme

- Section I. Les juges de la Cour
- Section II. La saisine de la Cour

Chapitre II. Le contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme

- Section I. L'examen de la recevabilité
- Section II. Le règlement amiable
- Section III. L'examen du fond de la requête
- Section IV. Les arrêts de la Cour

Titre II. La Cour de justice de l'Union européenne

Chapitre I. La Cour de justice

- Section I. L'organisation
- Section II. Les procédures

Chapitre II. Le Tribunal

- Section I. L'organisation
- Section II. Les procédures

PARTIE II – LES JURIDICTIONS INTERNES

Titre I. Le Conseil constitutionnel

Chapitre I. La composition

Chapitre II. Les compétences

- Section I. Le contrôle de constitutionnalité
- Section II. Les autres attributions

Titre II. Le Tribunal des conflits

Chapitre I. L'organisation et le fonctionnement

Chapitre II. Le traitement des conflits

Chapitre III. Les attributions au fond

Titre III. Les juridictions de l'ordre judiciaire

Chapitre I. Les juridictions civiles du premier degré

- Section I. Les juridictions civiles de droit commun
- Section II. Les juridictions civiles spéciales

Chapitre II. Les juridictions pénales

- Section I. Les juridictions pénales de droit commun
- Section II. Les juridictions pénales spéciales

Chapitre III. Les juridictions supérieures

- Section I. Les cours d'appel
- Section II. La Cour de cassation

Titre IV. Les juridictions de l'ordre administratif

Chapitre I. Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

- Section I. Les tribunaux administratifs
- Section II. Les cours administratives d'appel

Chapitre II. Les juridictions administratives spéciales

- Section I. Les juridictions financières
- Section II. Les juridictions spéciales non financières

Chapitre III. Le Conseil d'État

- Section I. Les attributions
- Section II. La section du contentieux

INTRODUCTION: Lorsqu'il évolue en société, le Sujet de Droit est titulaire de droits subjectifs : c'est le cas du droit de grève, la liberté de manifester, le droit à la vie privée, la liberté de réunion, la liberté d'expression (1881). Les droits subjectifs peuvent être définis comme des prérogatives individuelles, protégées et reconnues par le droit dit, que l'on appelle le droit objectif. La personnalité juridique est tirée du droit romain et elle fait référence à l'expression « personare » il s'agissait pour l'acteur, dès lors qu'il montait sur scène, de porter un masque pour faire raisonner sa voix. Il est important de savoir quand commence la personnalité juridique et par principe, la personnalité juridique commence à la naissance, à la condition de naître vivant et viable, et parfois le droit admet la possibilité de faire rétroagir (=reculer) la personnalité au stade de la simple conception. Notre Droit s'inspire du Droit romain et d'un adage selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Exemple : une femme enceinte décède, son enfant survit = problème d'héritage= on fait de sorte qu'il soit né pour l'héritage. C'est le célèbre adage « infans conceptus... » « l'enfant conçu est réputé à chaque fois que cela va en son intérêt. » Le Droit objectif peut être défini comme l'ensemble des règles socialement édictées et sanctionnées et qui s'imposent aux membres de la société. Il ne s'agit pas seulement de défendre, de protéger tel ou tel droit subjectif. Le Droit objectif peut poursuivre d'autres finalités que la seule garantie des droits subjectifs, que la seule garantie des droits individuels. Par exemple, les nécessités de la sécurité publique justifient des limitations, des restrictions aux droits de chacun, au respect de sa vie privée. Par exemple, les nécessités de la sécurité publique, justifient les visites à domicile d'agents de police, peuvent justifier les écoutes téléphoniques. Derrière cette notion de sécurité publique, il y a un concept juridique beaucoup plus large, que l'on appelle l'**ordre public**. L'ordre public se décompose généralement en trois aspects : la **sécurité publique**, la **salubrité** (la santé, ex : restrictions sanitaires) **publique** et la **tranquillité publique**. On fait référence ici à l'article L2212-2 du CGCT qui fait référence aux pouvoirs de police du maire (ex : à Aix en Provence il est interdit d'envoyer en l'air des nains car contraire à la dignité humaine et contraire à l'ordre public) et donne des indications sur ce qu'est l'ordre public. Dans le prolongement, il faut savoir que les nécessités de la protection de l'environnement peuvent justifier des restrictions à l'exercice de droits subjectifs, par exemple à l'exercice du droit de propriété. Le Droit objectif doit permettre l'articulation de l'existence et l'exercice des différents droits subjectifs qui peuvent entrer en conflit et parce que nous sommes dans un état de droit, nul ne peut se faire justice soi-même et donc la protection implique aussi l'existence d'une action en justice qui vise à protéger le Sujet de Droit. Le plus souvent, les personnes/les Sujets de Droit, exercent leurs droits sans difficultés, les propriétaires jouissent par exemple de leur propriété, de leur bien, sans être dérangé par les tiers. Le droit de propriété est défini par l'article 544 du code civil qui le définit comme le droit de jouir et de disposer de son bien. Le droit de propriété comporte l'Usus, l'Abusus et Fructus. Cependant, il arrive que les droits subjectifs fassent l'objet de contestation, par exemple, il y a conflit sur les limites d'une propriété immobilière, il y a conflit sur le caractère mitoyen d'un mur, par exemple, conflit sur l'exécution d'un contrat, conflit à l'occasion de la détermination des causes d'un accident. Il arrive que ces contestations soient réglées à l'amiable, dans ces hypothèses on va limiter ou éviter le passage devant le juge. On dit d'ailleurs que « **mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès** » **Honoré de Balzac dans *Les illusions perdues***. Car généralement on reproche à la justice sa lenteur. Mais à défaut d'accord, les parties litigantes seront amenées à recourir à la justice. Ils

seront amenés à procéder à une réalisation non pas amiable mais contentieuse de leurs droits. L'accès au Droit est par incidence l'accès à la justice, est un droit fondamental et, tout droit est assorti d'une sanction qui est la condition même de son efficacité. Et c'est pourquoi il faut faire appel à la justice pour faire sanctionner l'auteur des faits/du trouble et plus largement, pour faire sanctionner l'auteur des atteintes portées au Droit positif. En effet, nul ne peut se faire justice soi-même et nul ne peut être à la fois juge et partie ; c'est pourquoi la justice à ce pouvoir et, la sanction du Droit ne peut émaner que d'une autorité publique. Tout droit est muni d'une action en justice dont l'exercice donnera lieu à un procès. Et ceci vaut même pour le procès pénal que l'on peut déjà définir comme le tarif que la société en temps donné à un trouble porté à la paix sociale : la victime est la société. Et ce recours à la justice sera en principe porté devant une juridiction de l'état. Toute la question est de savoir ce qu'est la juridiction d'un point de vue étymologique : c'est l'organe en charge de dire le Droit, c'est la *jurisdictio* = dire le Droit. Il n'existe pas de conception unitaire de la juridiction mais on peut dégager de 2 conceptions de la juridiction, une est tirée du Droit interne, c'est-à-dire français et l'autre est tirée du Droit internationale, plus précisément de la Cour internationale des droits de l'Homme. S'agissant tout d'abord de la conception tirée du droit interne, à l'origine endroit interne, c'est un critère formel qui est utilisé pour caractériser la juridiction. Très simplement, c'est-à-dire que c'est l'organe qui a les traits d'un tribunal qui sera qualifié comme tel et bien plus le fait que l'organe ait été qualifié comme tel dans la Constitution ou dans la loi contribuera/suffira à retenir cette qualité de juridiction mais, il faut néanmoins que l'organe s'insère dans un système structuré et hiérarchisé avec à sa tête une Cour suprême : le conseil d'Etat pour l'ordre administratif et la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Il faut en plus/sus une certaine indépendance et d'une impartialité : ne pas être partial= ne pas prendre parti. Il y a 2 types de partialité : la partialité objective liée à la fonction (ex : le juge instruit l'affaire et se retrouve également dans l'instance de jugement) et la partialité subjective liée à la personne (le magistrat couche avec l'avocate). De façon complémentaire, pourront également être qualifiés de juridiction, les organes qui, en l'absence d'une telle dénomination par la loi ou la constitution, sont tenu d'appliquer une procédure juridictionnelle c'est-à-dire une procédure garantissant aux partis/sujets en conflit, le principe du contradictoire (entendre tous les points de vue) et plus largement le respect des droits de la défense. De façon plus contemporaine c'est un critère matériel qui tend à s'imposer en France conduisant à retenir parmi les juridictions des organes qui n'en n'ont pas les apparences et dès lors, va être qualifié de juridiction, l'organe qui aura pour mission de trancher un litige et tout simplement de dire le Droit. En effet, dire le Droit est la mission fondamentale de la juridiction, il s'agit tout simplement pour le juge de dire comment la loi générale et abstraite va s'appliquer au caractère particulier du litige qui lui est soumis. C'est d'ailleurs une obligation pour le juge, le Droit interne prohibe les arrêts de règlement, c'est la prohibition des arrêts de règlement article 5 du code civil. Il est interdit au juge de se prononcer par voix générale et abstraite. Le juge romain disait « *donne-moi les faits je te donnerai le Droit* ». S'agissant de la conception de la prohibition tirée de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : 2 points caractérisent la conception de la juridiction par la Cour Européenne des droits de l'Homme : tout d'abord, 1^e point, elle fonde les critères formels et matériels pour établir une liste d'indices qui vont la conduire à retenir ou non la qualification de juridiction. Elle utilise ce qu'on appelle la méthode dite du « faisceau d'indices », ces indices

sont notamment l'origine législative ou constitutionnelle de l'organe en question, l'application des règles de droit et non de la morale ou de l'équité, le caractère obligatoire de ces décisions, l'application du principe obligatoire du contradictoire, l'application des principes d'indépendance ou encore, d'impartialité etc. Quoiqu'il en soit, la Cour Européenne utilise la méthode du faisceau d'indices pour asseoir sa qualification et elle se reconnaît une grande marge d'appréciation c'est-à-dire, qu'il n'est pas nécessaire que tous les indices soient présents pour retenir la qualification de juridiction mais, si trop peu d'indices sont présents, alors, la cour décidera que l'organe en question n'est pas une juridiction. La cour européenne des droits de l'Homme se rapproche ici de la conception dégagée par le Conseil d'Etat français, en effet, ce conseil considère d'ailleurs qu'un organisme administratif au sens du droit français peut être qualifié de tribunal au sens du Droit du conseil de l'Europe, c'est un arrêt du Conseil d'Etat Assemblée (CE Ass) 3 décembre 1999, l'arrêt Didier. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que retient également le Conseil d'Etat français dans l'arrêt Didier, que sa méthode conduit à retenir plus largement la qualification de juridiction et par exemple pour un organisme administratif.

(L'affaire dite du bon juge Magnaud : un juge fin 1990 a fait face à une infraction commise par une mère de famille : volait des denrées alimentaires pour nourrir ses enfants : il était obligé de la condamner mais, avec les valeurs sociales il l'a étiqué car le droit pénal est difficile.)

CHAPITRE PRELIMINAIRE : LES PRINCIPES STRUCTURANT LA JUSTICE FRANCAISE

1^e principe : La justice est un monopole de l'Etat

2^e Le principe d'indépendance des juridictions

3^e Le principe de collégialité

4^e principe : le double degré de juridiction et la collégialité

- **SECTION 1 : LE MONOPOLE DE L'ETAT**

Rendre la justice est un attribut de la souveraineté mais il faut savoir que sous l'ancien régime, il n'y avait pas de monopole de la justice puisque, à côté des justices seigneuriales, il y avait la justice canonique en droit de la famille, et aussi, la justice royale. Par la suite la justice royale c'est progressivement imposé pour devenir la justice d'appel. Dans la nuit du 4 août 1789, les justices seigneuriales déjà particulièrement affaiblies ont été supprimées et c'est ainsi qu'est né le monopole de l'Etat pour rendre la justice. Mais il faut savoir que ce monopole implique un certain nombre de contrepartie. ; d'une part l'obligation de juger : en effet les juridictions étatiques ne sauraient refuser de juger par exemple au motif que la loi est obscure, que la loi n'est pas claire, c'est ce qu'on appelle le déni de justice et il faut savoir que le déni de justice est prohibé par l'article 4 du code civil qui dispose (**un article ou une loi dispose et un contrat stipule**) le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. D'autre part, ce monopole implique une obligation de bien juger conformément aux principes notamment posés par la lettre de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tout particulièrement à son article 6 paragraphe 1 de la Convention relatif au principe du contradictoire, au délai raisonnable, ou encore à l'égalité des armes entre les partis. Ce monopole, pour dire le vrai, a 2 nuances, il s'agit de l'arbitrage et de la transaction.

PARAGRAPHE 1 : L'ARBITRAGE

Le code de procédure civile prévoit en son **article 1442** que l'arbitrage peut revêtir 2 formes. D'une part la **clause compromissoire** et d'autre part le **compromis d'arbitrage**. La clause compromissoire est une disposition contractuelle par laquelle les partis à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourrait naître à l'occasion de l'exécution du contrat ; c'est l'article 1442 alinéa 2 du code de procédure civile. La différence entre la clause et le compromis est une question de temps. La clause, on anticipe, on décide l'arbitrage avant tout problème alors que le compromis c'est après tous problèmes. La clause compromissoire doit à peine/au risque de nullité avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose et, elle ne peut être opposée à la partie qui n'a pas contractée dans le cadre de son activité professionnelle. Par exemple, si on a un contrat de consommation (ex : téléphonique), en cas de problème, tout problème sera soumis à l'arbitrage, elle sera nulle car ce n'est pas

en situation professionnelle : le consommateur est une partie faible, il ne connaît pas le droit. En droit on protège la partie faible. C'est une relation B to C entre business et consommateur. La clause est donc admise entre commerçants (B to B) mais aussi à l'égard des artisans, des agriculteurs et des professionnels libéraux. Elle ne peut jamais être opposée à un consommateur. Quand un régime juridique né avant le litige c'est ex-ante (clause) et après c'est pro-ante (compromis). Le compromis d'arbitrage est lui aussi prévu à l'article 1442 du code de procédure et, il faut savoir que quelque soit la convention d'arbitrage conclue entre les parties, il y aura nomination d'un arbitre ou d'un tribunal, et, le compromis peut être défini comme la convention, le contrat par lequel les parties à un litige déjà né décident de soumettre celui-ci à l'arbitrage ; c'est l'article 1442 alinéa 3 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, le litige est déjà présent. Les parties peuvent décider de recourir à l'arbitrage y compris lorsque l'affaire est en Cours devant une juridiction, appelé une affaire pendante devant une juridiction étatique. Il faut savoir que, quel que soit la condition d'arbitrage, à savoir compromis ou clause compromissoire, l'arbitre ou le tribunal arbitral doit respecter certains principes de procédure, certains principes directeurs du procès civil, et tout particulièrement le droit et **les exigences à un procès équitable** que l'on retrouve/fondées des assises dans **l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde de Droit de l'Homme et des Libertés Fondamentales**. Il faut savoir que l'arbitre ou le tribunal arbitral peut se faire communiquer tous les éléments nécessaires afin de trouver une solution et il faut savoir qu'il peut ordonner aux parties toutes mesures conservatoires ou provisoires, éventuellement sous astreinte. C'est une obligation de faire ou ne pas faire assortie d'une pénalité économique.

Il faut savoir que l'arbitre ou le tribunal arbitral peut entendre les parties et peut même auditionner un tiers. En droit, il y a **2 catégories de tiers**. D'une part il y a le **tiers intéressé** par exemple, si on décide de faire une fête dans l'appartement et qu'on le saccage il y aura un conflit entre toi et le propriétaire, ici les tiers intéressés seront les voisins, les garants, l'agence... Ils ne sont pas directement concernés mais le sont indirectement. D'autre part, il y a les **tiers désintéressés** que l'on appelle des **penitus extranei**. En droit, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. L'arbitre ou le tribunal arbitral est censé appliquer les règles de droit mais, il peut se voir confier par les parties le soin de statuer en amiable compositeur. Dans cette hypothèse, il va se référer à l'équité. L'équité est un ensemble de règles morales, un jugement de valeur mais qui n'a pas pour fondement le droit c'est l'affaire du bon juge Magnaud. La sentence arbitrale va être rendue après délibération secrète à la majorité des voix, elle doit être motivée (justifiée, argumentée) pour éviter l'arbitraire et elle doit être signée de tous les arbitres. A la date de sa décision, la sentence a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle peut même être assortie de l'exécution provisoire. En revanche, contrairement aux décisions de justice étatique, elle ne bénéficie pas de la **force exécutoire**. Sur chaque jugement étatique, est apposée une formule « **La République mande et ordonne à tous les huissiers de pouvoir recourir à la force publique pour faire exécuter le jugement** ». La sentence arbitrale n'a pas de force exécutoire, autrement dit, si une des parties refuse d'exécuter la sentence, il faudra pour l'autre partie saisir un juge du tribunal judiciaire pour obtenir l'exécution forcée ; le juge doit rendre alors une décision d'*exequatur*. L'*exequatur* est une procédure qui peut s'appliquer à la sentence arbitrale mais qui

généralement désigne la possibilité de faire appliquer dans l'ordre interne français un jugement étranger. Il existe des voies de recours contre la sentence arbitrale, en effet, il est important de noter qu'en principe, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties. Dans cette hypothèse, s'il y a appel, un recours est alors porté devant la Cour d'Appel qui peut statuer en Droit mais aussi en amiable composition (fait référence à l'équité). Néanmoins, il reste toujours possible de former un recours judiciaire en annulation devant la cour d'Appel. Toute clause contraire c'est-à-dire toutes clauses qui interdiraient ce recours en annulation, est réputée « non écrite », c'est une astuce procédurale pour neutraliser cet aspect. Les cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence arbitrale sont strictement prévus par l'article 1492 du code de procédure civile, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre cas que ceux énumérés par cette disposition, on dit que cette **liste est limitative**. En substance, l'article 1992 dispose que « **le recours en annulation n'est ouvert que si, premièrement le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent, si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué, si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la lettre de missions qui lui avait été confié, si le principe de la contradiction n'a pas été respecté (article 15 et 16 du Code de procédure civile envisage la contradiction), si la sentence est contraire à l'ordre public (salubrité, tranquillité, sécurité), si la sentence n'est pas motivée, n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue, n'indique pas le nom du ou des arbitres, la signature de l'un ou des arbitres ou encore si elle n'a pas été rendue à la majorité des voix** ».

PARAGRAPHE 2 : LA TRANSACTION

La transaction est une procédure qui est prévue par le code civil et elle se rencontre en matière civile. Elle est l'illustration même de l'adage « mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». La transaction est un contrat écrit sans recours à une juridiction mais, la difficulté est que la transaction a autorité de choses jugées, c'est l'article 2052 du code civil, elle a autorité de chose jugée mais elle n'a pas de force exécutoire. Il faut savoir qu'elle se retrouve aussi en matière pénale mais elle nécessite l'accord du procureur de la République. Elle est possible en matière de délinquance écologique, dans cette hypothèse le préfet va transiger avec la personne poursuivie et va proposer une amende transactionnelle et bien souvent, il propose la remise en état des lieux. Dans l'hypothèse d'un accord, la transaction est alors homologuée (une validation par une autorité compétente) par le procureur de la République car son rôle est de défendre les intérêts de la société.

(Les présomptions étaient définies à l'ancien article 1349 du code civil « **les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait inconnu** ». Il y a **3** catégories de **présomptions** en droit français : les **présomptions simples** ; les **présomptions mixtes** appelées aussi **présomptions légales** ; les **présomptions irréfutables**. La **présomption simple** est celle qui peut toujours être renversée par la preuve contraire et par tous moyens (écrits, témoignages etc.). Par exemple : en simple possession de meubles, celui qui détient un objet meuble est réputé en être la propriété mais celui qui en acclame la propriété peut rapporter la preuve de sa propriété par tous moyens.

La **présomption mixte** est celle dont on peut rapporter la preuve contraire mais dans les conditions prévues par la loi (ex : la présomption de paternité : le mari de la mère de l'enfant

est présumé être père de l'enfant, c'est la présomption patres is este). La **présomption irréfragable** est celle qu'on ne peut renverser, dont il est impossible de rapporter la preuve contraire. C'est par exemple l'acte authentique, le testament authentique. L'acte authentique est celui qui est établi par un officier ministériel c'est-à-dire celui qui est établi par le notaire. Néanmoins, il est parfois possible, en certaines circonstances, de rapporter la preuve contraire, notamment au moyen de la procédure dite de l'inscription en faux. Par exemple, le notaire qui va avoir sciemment établi un acte dans le but de nuire à certaines personnes ; la preuve de l'intention de nuire est très difficile à rapporter. Il existe un principe très important en Droit français : il est équivalent de ne pas avoir de droit et de ne pouvoir le prouver. Cela est dû au droit romain, c'est l'adage *Idem est esse aut non probari*.)

- **SECTION 2 : L'INDEPENDANCE DES JURIDICTIONS**

La séparation des pouvoirs est dû à Montesquieu dans son ouvrage de *'Esprit des lois*. Elle exige une certaine indépendance des juridictions par rapports aux autres fonctions de l'Etat. **L'article 64 de la constitution** est très important en la matière puisqu'il dispose que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. L'indépendance de l'autorité judiciaire trouve également son fondement à **l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne** de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Concrètement, les juridictions doivent être **indépendantes** du pouvoir législatif, en effet, il appartient au législateur d'édicter des lois qui peuvent être sommairement définies comme des normes générales et impersonnelles et il appartient aux juridictions de les appliquer.

(La hiérarchie des normes est l'idée selon laquelle toutes les normes s'organisent suivant un système pyramidal avec au sommet une norme fondamentale qui est généralement la Constitution. Suivant ce système, chaque norme tire sa validité de sa conformité à la norme qui lui est immédiatement supérieure jusqu'à atteindre la norme fondamentale au sommet, à savoir la Constitution. Dans notre droit, au sommet de la hiérarchie il y a certes la Constitution à savoir la Lettre (l'écrit) de la Constitution du 4 octobre 1958 mais il y a également d'autres textes que l'on appelle blocs de constitutionnalité qui ont été forgés avec la fameuse décision **liberté d'association en date du 25 juillet 1971**. Il y a certes un texte (Constitution) mais ce texte contient un préambule, ce préambule renvoie au préambule de la Constitution de 1946 qui lui-même renvoie notamment à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. En somme, le bloc de constitutionnalité et la Constitution mais pas que (ex : DDHC etc.))

Si le juge faisait exclusivement référence à la loi et ne s'intéresse pas au cas particulier qui lui est soumis, il rend un arrêt de règlement, il tombe alors sous le coup de la **prohibition des arrêts de règlements** conformément à **l'article 5 du code civil**. Les juges ne peuvent en principe pas écarter la loi mais, il y a une exception : il en va différemment lorsque la loi est contraire à un traité international, il est possible de l'écarter : c'est **l'article 55 de la Constitution**. Il est possible aussi au **juge d'écarter la loi** contraire à la constitution dans le cadre particulier de la procédure de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). **L'article 55 de la constitution** dispose que les *traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour*

chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie (ou les autres parties). C'est ce qu'on appelle le **principe de réciprocité**. D'autre part, les juridictions ne doivent pas empiéter sur les pouvoirs du législateur et c'est pour cette raison que sont prohibés les arrêts de règlement. Ces arrêts ont été une pratique courante jusqu'en 1789. Il faut savoir que, par arrêt de règlement on désignait les actes des parlements d'anciens régimes et plus précisément leur décision, qui étaient de portée générale et abstraite. De portée générale veut dire *erga omnes* : à l'égard de tous ; à la différence d'entre les partis : *inter partes*. Ces arrêts des parlements valaient même pour l'avenir, ils avaient la forme d'une loi ; c'est pourquoi, on a considéré que ces arrêts de règlement portés atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs car, le juge des parlements se substitua au législateur. Les rédacteurs du code civil (ex : Portalis ou Bigot de Préameneu) ont prohibé les arrêts de règlements, c'est l'article 5 du code civil : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générales et abstraites sur les causes qui leur sont soumises. ». Cependant, ceci ne veut pas pour autant dire que tout arrêt de principe est interdit. En effet, les arrêts de principe existent et ces arrêts font office de jurisprudence. C'est-à-dire que leur portée symbolique est telle qu'ils viennent à s'imposer pour l'avenir aux autres cas similaires. De la même manière, il faut savoir que le législateur ne peut pas intervenir dans la fonction de juger, les exceptions sont très rares, on peut mentionner la rétroactivité des lois. En effet, c'est par exemple le cas de la loi pénale. Lorsque, au cours d'une instance, une loi pénale **plus douce** intervient, on va l'appliquer au procès en cours. C'est ce qu'on appelle le principe de la rétroactivité *in mitius*.

(Tout notre Droit pénal repose sur le principe de la légalité des délits et des peines, principe que l'on doit à Cesare Beccaria qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Traité des délits et des peines, dans lequel est exposé un principe très important suivant lequel « **pas de crime, pas de peine sans l'existence d'une loi préalable** » qui se dit « *nullum crimen nulla poena sine lege* ». Ce principe implique que l'on ne peut rechercher la culpabilité de l'auteur d'une contravention, d'un délit, ou d'un crime s'il n'existe pas de dispositions textuelles (lois ou règlements) préalables. Il y a ensuite un autre principe structurant, **l'interprétation stricte** du texte pénal, et enfin, la **non-rétroactivité** de la loi pénale par principe, sauf lorsque la peine encourue est plus douce. C'est ce qu'on appelle la rétroactivité *in mitius*. Le texte de loi qui prévoit les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue s'appelle **l'incrimination**. Le **quantum** de la peine c'est la portion de peine qu'on encourt, le seuil de peine, le maximum.)

La première exception est la loi rétroactive. Il existe finalement des lois de validation de décision administrative illégale. Les juridictions doivent être indépendante du pouvoir législatif, et doivent être indépendante du pouvoir exécutif. Il faut savoir que les juges administratifs peuvent contrôler la légalité des décisions de l'administration mais, en aucun cas, les juges administratifs ne peuvent se substituer à l'administration dans sa fonction d'administré. D'ailleurs, le juge judiciaire, notamment le juge pénal, peut parfois condamner un responsable de l'administration qui a commis une faute pénale dans l'exercice de ses fonctions (le maire qui autorise une sortie dans un barrage -> donne lieu à des morts : le maire a commis une faute dans l'exercice de sa fonction). De la même manière, le pouvoir exécutif ne peut influencer les juges. C'est plus difficile pour les juges administratifs parce que l'indépendance du Conseil d'Etat à l'égard du pouvoir en place n'est pas toujours évidente.

- SECTION 3 : LE PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE

On dit parfois « **juge unique, juge inique** ». Un juge inique est une personne qui contrevient (manque) à l'équité. L'équité c'est la neutralisation de l'application sèche de la règle de droit au profit d'une considération morale et c'est par exemple l'affaire du bon juge Magnaud. C'est pourquoi, on a tendance à préférer la collégialité. La collégialité implique un tribunal ou une cour, statut avec plusieurs magistrats. Il s'agit là d'une coutume, d'une tradition. Lorsque la coutume va dans le sens de la loi on dit qu'elle est *praeter legem* et lorsque la coutume est contraire à la loi on dit qu'elle est *contra legem*. Pour qu'une coutume ait une valeur juridique, il faut qu'elle soit suivie et répétée dans le temps. Il est possible, notamment pour les praticiens et tout particulièrement en droit des affaires, de conférer une plus grande valeur juridique à une coutume ou à un usage en demandant, en sollicitant sa validation, sa reconnaissance par une organisation professionnelle et tout particulièrement par une chambre de commerce et d'industrie. Dans cette hypothèse, l'organisme professionnel pourra délivrer un document qui validera l'usage, ce document s'appelle **un parere**.

Le principe de collégialité n'a pas de protection constitutionnelle. En effet, le **conseil constitutionnel**, appelé aussi **les sages de la rue Montpensier**, dans un **décision DC**, du 14 octobre 2010, a considéré que le principe de collégialité n'avait pas d'assises (de fondement) constitutionnelles. Le principe de collégialité ne bénéficie également d'aucune protection d'un point de vue européen. Ainsi, la lettre (=le texte) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales est taiseuse sur ce point. Tout particulièrement, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que le principe de collégialité n'est pas une exigence du Droit au procès équitable que l'on retrouve à l'article 6 paragraphe 1 du texte de la convention européenne. Pour des raisons d'économies budgétaires, le législateur n'hésite pas à multiplier les hypothèses de juges uniques. On convient de noter que la **loi du 23 mars 2019**, dite de programmation et de réformes pour la justice a opéré une très importante modification de la répartition de contentieux entre le juge unique et la collégialité en substance, la collégialité n'est plus de Droit pour les partis, c'est l'article I qui fait référence à la partie législative (et d c'est la partie décréte) l'article I212-2 du code de l'organisation judiciaire. La décision de renvoi à la collégialité est une mesure d'administration judiciaire (car on ne peut pas faire de recours) décidée d'office par le juge unique ou à la demande des partis. Cette loi a considérablement élargi les domaines de pleins Droit (pas obligé de le demander, d'office) dans lesquels le juge unique est compétent. Il faut savoir que la collégialité peut impliquer que certaines missions soient confiées à un juge unique. Par exemple, on peut laisser à un juge unique le soin d'écouter les partis voir, le soin d'établir des rapports. Néanmoins, un minimum d'échange doit avoir lieu entre l'organe collégial et le juge unique, tout particulièrement sur les questions délicates qui vont bien souvent nécessiter un surcroît d'investigations.

- SECTION 4 : LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION

Le principe de double degré de juridiction implique que le justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue une nouvelle fois par une juridiction supérieure. Par exemple, s'agissant de l'ordre judiciaire, lorsque le justiciable n'est pas satisfait du jugement rendu par le tribunal judiciaire, il a le droit de former un appel devant la cour d'appel. Celui qui fait appel est appelé « **l'appelant** » et celui qui doit se défendre en appel est dénommé « **intimé** ». Devant la juridiction administrative, lorsque le justiciable, souvent un administré, n'est pas satisfait du jugement rendu par le tribunal administratif, il va pouvoir faire appel, par principe, devant la Cour administrative d'Appel. Devant le tribunal administratif, lorsque le justiciable n'est pas satisfait du jugement rendu, il pourra parfois faire appel devant une autre juridiction : le Conseil d'Etat. C'est tout particulièrement le cas en matière de procédure d'urgence comme le référé-liberté qui est prévu à l'**article I521-2 du code de justice administrative** par la loi du **15 juin 2000**. Lorsque l'on dit que la cause doit être doublement entendue, il s'agit d'une **analyse en fait et en droit**. Bien souvent, pour des raisons d'économies budgétaires, le législateur a tendance à multiplier les hypothèses dans lesquelles le juge saisi statuera en premier et dernier ressort. Il est impossible, dans une telle hypothèse, de faire appel. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il n'existe plus de recours, en effet, bien souvent, le pourvoi en cassation reste possible. Les hypothèses dans lesquelles le juge statue en premier et dernier ressort sont bien souvent celles qui présentent un faible intérêt pécuniaire, relatif à l'argent. Ici, on fait encore référence à un vieil adage romain « **des affaires minimes, le juge ne se préoccupe point** » en latin « de minimis nom curat praetor ».

- SECTION 5 : LA PUBLICITE

On est dans un Etat de droit, l'**Etat de Droit implique l'existence d'un corpus de règle ayant pour finalité de maintenir la paix sociale** pour éviter de donner l'envie à un justiciable de se faire justice soi-même. Comme on est dans un Etat de Droit, nul n'est censé ignorer la loi ; il s'agit là d'une pure fiction juridique : tant les textes sont nombreux et leur application jurisprudentielle sont nombreuses.

La publicité permet de rendre opposable sa situation juridique aux autres sujets de droit et donc de garantir la paix sociale. Suivant cette même logique, la justice est rendue de façon transparente. Les audiences sont bien souvent publiques sauf cas particulier : par exemple le huis-clos au pénal ou encore en chambre du Conseil (pour le civil). D'une manière générale, le respect de la publicité est une exigence posée pour garantir le droit au procès équitable, qui a pour fondement l'**article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne** qui dispose que « **toutes personnes a droit à ce que ça cause soit entendue publiquement.** ». La publicité des audiences est garantie par la loi, par le **code de l'organisation judiciaire à l'article I112-12** et par le **Code de Justice Administrative (CJA) à l'article I6**. (*Obiter dictum* signifie *soit dit en passant*.)

Toute personne peut y assister même si elle est sans lien avec les partis. Il en va également ainsi des journalistes qui peuvent rendre compte dans les médias des audiences mais que ne sont pas autorisés à enregistrer ou encore à filmer les débats. Il existe un métier peu connu :

le croqueur d'audience, il dessine l'audience. Dans le but de protéger la vie privée des personnes vulnérables, des audiences à huis-clos peuvent toutes fois être organisées.

Il y a la publicité des débats mais également la publicité des arrêts et jugements. Il faut savoir que le code de justice administrative article L-10 et le code de l'organisation judiciaire article L111-13 prévoit la publicité des arrêts et jugements. La plupart des décisions de justice font même l'objet d'une diffusion sur des sites internet et tout particulièrement sur le site Légifrance dont l'accès est gratuit. Il existe d'autres supports internet et tout particulièrement des sites de justice prédictives, c'est-à-dire des sites qui, en fonction des données de votre affaire, sont capables de vous dire les chances que vous aurez de gagner et même, d'anticiper sur l'issue du procès et plus précisément sur les sommes que vous pourriez potentiellement obtenir ; c'est le cas de Predictis, Doctrine, Case law Analytics, ou encore des domaines particuliers). Un moteur de recherche a été mis en place en collaboration avec le cabinet Auguste et Debouzi en droit des affaires ou encore le cabinet Vogel et Vogel spécialisé en droit à la concurrence. Dans tous les cas, les décisions de justice font aujourd'hui l'objet d'une anonymisation, notamment lorsqu'il s'agit de personnes physiques, tout ceci dans le but de protéger leur vie privée.

PARTIE 1 : LES JURIDICTIONS EUROPEENNES

Lorsque l'on évoque les juridictions européennes, on fait référence à la Cour Européenne des Droits de l'Homme mais aussi, à la Cour de Justice de l'Union Européenne. **Le Droit européen est constitué de 2 branches :**

- **Le système de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme** et donc de la **Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme** en charge de son application
- Le **système de l'Union Européenne**, que l'on appelle encore injustement « droit communautaire », qui se compose des traités Européens, à savoir le Traité sur l'Union Européenne, mis en place à Maastricht en 1992, et le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. L'organe en charge de l'application de ces traités est la **cour de justice de l'Union Européenne** (la CJUE).

Depuis 2009, on ne doit plus parler de droit communautaire mais de **droit d'union**.

TITRE 1 : LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

La Cour Européenne des Droits de l'Homme assure le respect des droits et libertés qui sont garantis tout à la fois par la lettre de la convention européenne, mais également, par ses protocoles. On peut ainsi mentionner **l'article 1^{er} du 1^{er} protocole** qui garantit le droit au **respect de ses biens**, qui n'est ni plus ni moins le **droit de propriété prévu par l'article 544 du code civil**, mais dans une conception, une version plus dynamique.

Lorsque l'interprétation que l'on réalise vise à déterminer le sens du texte, on dit que l'on réalise une interprétation **téléologique**. La **Convention Européenne de Droit de l'Homme** et

des Libertés Fondamentales ; a été **signée le 4 novembre 1950** et a été **ratifiée par la France en 1974**. Elle est inspirée de la **Déclaration Universelle des Droits de l'Homme** qui date du **10 décembre 1948** et qui constitue un véritable instrument juridique obligatoire, on dit **d'un texte qu'il est obligatoire lorsqu'il présente un caractère coercitif qui veut dire contraignant**. En effet, il existe des sources de droit non obligatoires c'est-à-dire **dépourvues de tout caractère contraignant** : il s'agit des instruments de **droit souple**, que l'on appelle **Soft Law**. L'article 1240 dispose que « *tout fait quelconque de l'Homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer* », pour caractériser la faute au sens de l'article, le juge va prendre appui généralement sur des instruments de droit souple que sont par exemple les guides de bonnes pratiques ou les recommandations. Il faut savoir que, moins une norme est élevée dans la hiérarchie des normes, plus elle va avoir des effets concrets pour ses destinataires, c'est ce qu'on appelle le **paradoxe de la concrétisation (voir Précis Dalloz)**. La **convention européenne** constitue un instrument juridique obligatoire pour les états signataires. Depuis son entrée en vigueur, le **3 septembre 1953**, ont été adoptés 16 protocoles additionnels.

Ces protocoles peuvent par exemple :

- soit ajouter des droits et libertés à ceux reconnus par la convention (par exemple : l'interdiction générale de toutes discriminations ou encore de l'abolition générale de la peine de mort). Le droit au respect de ses biens est prévu quant à lui par l'article 1^e du 1^e protocole additionnel.
- soit déterminer des éléments relatifs à la procédure applicable devant la Cour. C'est le cas du protocole n°16, entré en vigueur le 1^e août 2018 et qui permet à la Cour de rendre des avis consultatifs.

La **convention européenne** protège un ensemble de droit et liberté qui ont une nature essentiellement **civile et politique**, il s'agit tout à la fois de **droits substantiels mais aussi de droits procéduraux**. C'est-à-dire des droits attachés à la procédure et notamment à la qualité de la procédure, il s'agit notamment des garanties du **procès équitable**, prévu par l'**article 6 paragraphe 1** de la Convention Européenne de Sauvegarde. On n'y retrouve **pas** dans cette lettre, les droits à caractères **économiques ou sociaux**, à l'exception de la liberté syndicale qui se trouve liée à la liberté d'association et du droit à l'instruction. Il faut savoir que, lorsqu'on évoque la liberté syndicale, il s'agit de la liberté de se syndiquer mais aussi la liberté de ne pas se syndiquer, et de ne plus se syndiquer ; il en est de même pour la liberté d'association. Ces droits économiques et sociaux sont également protégés par un autre texte du Droit européen : il s'agit de la **Charte sociale européenne qui date de 1961** mais qui est assortie d'un contrôle moins contraignant ; on se rapproche des instruments de **soft Law**.

Au sein de la convention, on retrouve

- la garantie du Droit à la vie
- la liberté et le droit à la sécurité de la personne
- **droit au respect de la vie privée et familiale (article 8)**

- la **liberté d'expression (article 10)**
- la **liberté de pensée, de conscience et de religion (article 11).**

Dans la lettre on retrouve également le droit de vote ou encore le droit d'être candidat des élections, on retrouve le droit de posséder des biens. Originellement, le code civil été envisagé comme un outil **purement patrimonial** ; si on prend la sculpture de notre code civil, il est ainsi divisé des différentes manières dont on acquiert la propriété, des différentes manières dont on transfère la propriété : **les rapports juridiques sont essentiellement patrimoniaux**, même le mariage se trouve dans un rapport purement patrimonial. Ce n'est qu'en **1994 avec les lois bioéthiques** que le code civil s'intéresse véritablement au **corps et à la personne, avec les articles 16 et suivant** ; ceci s'explique par les traditions judéo-chrétiennes et par une formule particulière « *noli me tangere* ».

La convention européenne pose des interdictions

- l'interdiction de la peine de mort, de la torture ou encore des traitements inhumains ou dégradants (voir KA et AD contre Belgique)
- **l'interdiction de l'esclavage ou du travail forcé (article 4),**
- **l'interdiction de toute détention arbitraire** que l'on appelle le droit à la sûreté (**article 5 de la convention**)
- interdiction de l'expulsion ou du refoulement par un Etat de ses propres ressortissants ainsi que l'expulsion collective d'étrangers
- l'interdiction de toutes les discriminations dans la jouissance des droits reconnus par la lettre de la convention. Une **discrimination c'est un traitement juridique différent opéré entre des Sujets de Droit, placés dans une situation juridique équivalente.**

La convention a institué un mécanisme de contrôle juridictionnel international unique, il s'agit de garantir le respect des droits et libertés, et tout particulièrement, la Cour européenne des Droits de l'Homme a la charge de ce contrôle (bonne mise en œuvre des droits et libertés) par les **47 états membres du Conseil de l'Europe.**

CHAPITRE 1 : L'ORGANISATION DE LA COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME

Cette Cour a été mise en place en **1959** et fonctionne de manière permanente.

• SECTION 1 : LES JUGES DE LA COUR

Le juge islandais **Robert Spanos** est le plus jeune **président** jamais élu de la Cour européenne des Droits de l'Homme (47 ans) depuis le 18 mai 2021.

PARAGRAPHE 1 : L'ELECTION DES JUGES

La cour se compose de **47 juges** élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la base du principe suivant : **un état signataire égale un juge**. Ils sont élus pour un mandat de **9 ans non renouvelable**, depuis l'entrée en vigueur n°14 ; auparavant, les juges étaient élus pour 6 ans renouvelable. La limite d'âge de 70 ans a été supprimée le 1^e août 2021 et, elle a été remplacée par une limite d'accès aux fonctions : les candidats doivent être âgés de **moins de 65 ans** à la date à laquelle ils sont élus. Selon **l'article 21 de la Convention**, il est précisé que « *les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et doivent réunir les conditions requises pour l'exercice de haute fonction judiciaire ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire* (ex : prof de droit). *Les juges sièges à la Cour à titre individuel* (le juge ne représente pas les intérêts d'un état signataire) ». Les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requises pour exercer une activité à temps plein pendant la durée de leur mandat (on ne peut exercer aucune autre fonction pendant cette durée). Seuls les juges peuvent décider, à la majorité des 2/3, de relever de ses fonctions un juge qui a cessé de répondre aux conditions requises.

PARAGRAPHE 2 : LES FORMATIONS DE JUGEMENT

La **Cour Européenne**, siégeant en Assemblée plénière, aussi appelé Cour plénière, va **élire** son **président** pour un durée de **3 ans**. Ce président **dirige les travaux et les services de la Cour**, il **représente** la Cour, tout particulièrement avec les autorités du Conseil de l'Europe. Les juges sont organisés en **5 sections**, composées de **chambres de 7 juges** et d'un **comité de 3 juges**. Il existe également une **grande chambre** qui est composée de **17 juges** et elle constitue une formation solennelle (qui a de l'importance) de jugement, elle est aussi un organe de révision des arrêts rendus par les chambres.

Lorsque l'on évoque les **formations** de jugement au sein de la Cour européenne, il en existe donc **5** :

1. Tout d'abord les **formations de juges uniques**. Ces formations ont été instituées par le **protocole n°14** pour améliorer le filtrage de requêtes. Le nombre des juges uniques ainsi que leur nomination relève de la compétence du président de la Cour. Le juge unique examine les requêtes qui sont manifestement irrecevables, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de fondement. Il peut les rejeter ou les transmettre à un comité de 3 juges ou à une chambre pour un examen complémentaire.

2. La **formation des comités de 3 juges** qui sont constitués par les **chambres de la Cour** pour une **durée déterminée** et, ils ont compétence pour **déclarer irrecevable une requête** si elle ne mérite pas un examen approfondi. Selon le **protocole n°14**, leur compétence est même étendue aux **affaires répétitives**, autrement dit, dans le cadre d'une procédure simplifiée, ils sont **habilités à décider du fond d'une requête** quand la question posée a fait l'objet d'une réponse bien établie par la Cour.

3. La **chambre de 7 juges** est constituée du **président** de la section à laquelle l'affaire est attribuée, elle est composée **du juge national**, à savoir le juge qui est élu au titre de l'Etat contre lequel la requête a été introduite, ainsi que de **5 autres juges** désignés par le président de la section.

4- La **grande chambre** est composée de **17 juges**, il y a le **président** de la **Cour** et aussi le **juge national**. La grande chambre a compétence pour se **prononcer sur des questions graves**, concernant l'interprétation de la convention ou de ses protocoles ou encore, lorsque l'on pressent un revirement de jurisprudence, c'est-à-dire, une contradiction avec un arrêt de la Cour qui a été rendu précédemment.

La grande chambre peut être **saisie de 2 manières** :

- À la suite d'un **renvoi** quand un **arrêt de chambre** a été rendu et que les partis demandent le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Il s'agit d'une situation exceptionnelle qui nécessite un **examen préalable** par une structure particulière que l'on appelle le collège de la grande chambre.
- A la suite d'un **dessaisissement d'une chambre** dans des cas exceptionnels, lorsque se pose une question grave concernant l'interprétation de la Convention ou, lorsqu'il y a un risque de contradiction avec une décision, un arrêt déjà rendu par la Cour : on pressent un revirement de jurisprudence

5. **L'assemblée plénière** n'a pas de fonction contentieuse, elle exerce seulement des **fonctions administratives**, par exemple, elle a la charge d'établir le **règlement intérieur** de la Cour ou, de l'organisation des **élections** du président ou encore des vice-présidents de la Cour.

• SECTION 2 : LA SAISINE DE LA COUR

La **Cour peut être saisie** d'une part par les **états participants** à la convention, c'est ce qu'on appelle le **recours étatique** et ; d'autre part, directement par **des particuliers**, c'est ce que l'on appelle le **recours individuel** depuis le **1^{er} novembre 1998**, c'est-à-dire, depuis la date d'entrée en vigueur du **protocole n°11** qui a été signé le 11 mai 1994 et qui a profondément **modifié l'organisation** de la procédure en la rendant plus **simple** et plus **rapide**.

PARAGRAPHE 1 : LES RECOURS

Le **recours étatique** est très **rare** en pratique, mais, en théorie, il permet à chaque états signataires de la convention de saisir la cour en cas de **violation de la lettre de la Convention**

ou de ses protocoles par un autre état signataire, dans cette hypothèse, la nationalité des victimes n'a pas d'importance, l'accord de l'état mis en cause n'est pas demandé et enfin, le **recours est objectif**, il s'intéresse à la violation seule et on fait abstraction (faire fit) des intérêts individuels. **Tout état signataire peut agir** en invoquant la violation de la convention et de ses protocoles, c'est-à-dire en invoquant une violation de l'ordre public européen et donc, l'état qui met en branle (en mouvement) le recours étatique n'a pas à justifier de la violation d'un intérêt quelconques et plus particulièrement, il n'a pas à justifier d'un intérêt quelconque.

Les **recours individuels** constituent la **majorité** du flot contentieux. Le recours individuel est ouvert à toutes personnes physiques, à toutes personnes morales de droit privé ainsi qu'à tout groupe de particuliers. En droit français, il est possible pour un groupe de particulier **d'ester (agir)** en justice, par exemple s'agissant d'un groupe de consommateurs pour les préjudices qu'ils auraient subis à l'occasion de l'achat d'un bien de consommation. C'est ce que l'on appelle l'action collective ou encore la class action. La class action permet de rendre plus effectif le droit d'agir en justice. Pour reprendre l'exemple des consommateurs, bien souvent, le consommateur hésitait à agir en justice, lorsqu'il subissait un dommage patrimonial consécutif à l'achat d'un bien de consommation. En effet, il établissait un bilan « coût - avantages » et bien souvent renonçait à agir en justice.

Le **recours individuel** ne peut **pas être abstrait**, c'est-à-dire qu'il est conditionné, subordonné par l'existence d'un intérêt à agir du requérant particulier qui doit être directement ou indirectement victime. Une victime c'est un sujet de droit qui va subir une atteinte généralement de nature patrimoniale. C'est par exemple la perte d'argent, la perte pécuniaire ou encore la perte d'un bien ; a contrario, cela peut être l'absence d'économie attendue, espérée.

La jurisprudence de la cour européenne reconnaît toutefois la possibilité pour des tiers intéressés d'ester en justice devant elle, quand bien même ces tiers ne sont pas directement victime. On songe ici tout particulièrement aux proches d'une personne décédée. Le **défunt** en droit est généralement appelé « **de cujus** », néanmoins, la formule exacte c'est « *is de cujus successionne agitur* » ce qui littéralement veut dire « celui de la succession de laquelle il s'agit ». Les proches du défunt ont un intérêt à agir devant la cour européenne des droits de l'Homme. On note aussi que, le requérant peut être une victime potentielle dès lors que, la législation de son pays, c'est-à-dire que telle ou telle disposition d'une loi, peut lui être préjudiciable. Il y a ici un risque d'atteinte. Néanmoins, dans cette hypothèse, il doit fournir des raisons plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance de la violation dont il subirait personnellement les effets. Il faut savoir que, le requérant perd son droit de recours si les autorités nationales reconnaissent la violation et y apportent les correctifs nécessaires. En somme, il existe une faculté de repentir pour les autorités nationales.

PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

S'agissant de la procédure, il faut distinguer 2 types de procédure, la procédure principale et les procédures spéciales.

- La **procédure principale** est une procédure contradictoire ; elle comporte deux phases, une phase écrite avec le dépôt des mémoires et une phase orale avec les audiences de la Cour qui sont généralement publiques sauf si l'intérêt de l'une des parties justifie de ne pas mettre en œuvre le caractère public (une forme de confidentialité). Des tiers peuvent intervenir lors de la procédure notamment pour rapporter leurs savoir faire particulier sur une question technique. Devant la cour européenne il s'agit notamment des associations (Greenpeace par exemple) ou encore des ONG organisations non gouvernementales. Enfin, la cour peut demander des renseignements utiles aux partis et elle peut même ordonner certaines mesures provisoires aux Etats signataires et, si l'Etat signataire fait montre de résistance (refuse), il s'agit là d'une violation de la convention. La cour européenne dépose ici de pouvoirs étendus et peut même ordonner des mesures d'instruction. Par exemple, une visite sur les lieux au sein d'une administration ou une audition de témoin.

- à côté de la procédure principale devant la cour européenne, il peut y avoir d'autres procédures. Il s'agit par exemple du **réexamen par la Grande chambre** des affaires apportées devant une chambre. Il s'agit aussi du **recours en interprétation** qui permet à la Cour d'expliquer son arrêt et d'expliquer les recours. Ceci est possible même lorsque l'arrêt est devenu définitif. Ce retour en interprétation est très important pour les garanties de l'Etat de Droit. En effet, L'Etat de droit prend appui sur le principe de sécurité juridique et, l'Etat de droit repose sur un postulat, un principe, « nul n'est censé ignorer la loi ». Pour que ce postulat soit effectif, il faut que chaque sujet de droit connaisse la loi mais aussi les modalités d'application de la loi. Le sujet de droit doit bien connaître la loi et les modalités d'application c'est pourquoi, l'Etat de droit prend appui sur le principe de **sécurité juridique** qui a plusieurs branches, incidences :

- la **prévisibilité** de la norme : le texte doit être préalable (antérieur) à la situation juridique

- l'**intelligibilité** de la norme appelée aussi **accessibilité intellectuelle** : le texte doit être adapté et compris par ses destinataires

- **accessibilité matérielle** : pour permettre l'opposabilité du texte.

Le principe de sécurité juridique a été dégagé par le conseil constitutionnel dans une décision DC de 2003, la décision CRISTAU. La Cour Européenne des droits de l'Homme, par le recours en interprétation, en expliquant l'arrêt et la portée interprétative de ses arrêts se met en conformité avec le principe de sécurité juridique et tout particulièrement avec l'accessibilité intellectuelle de sa jurisprudence.

Il existe également dans les procédures spéciales, le **recours en révision**. Il est prévu pour le cas où il y a découverte d'un fait qui n'existait pas, qui n'était pas connu, au moment où la cour a rendu son arrêt. La découverte de ce fait, fait changer le droit et impose un recours en révision. Ce recours en révision est possible même lorsque l'arrêt est devenu définitif. Un arrêt ou un jugement est dit définitif lorsqu'il est insusceptible de recours.

En procédure spéciale il y a aussi la procédure dite **des arrêts pilote** : elle permet d'appliquer un traitement uniformisé à une série de contentieux (problèmes) similaires qui vont être amenés à se poser devant le juge. Autrement dit, la Cour précise que tous les contentions à

venir de même nature et de même objet devront être traités de la même manière que la solution juridique qu'elle expose. Par exemple, dans une affaire concernant la législation de la Pologne, la législation polonaise prévoyait que les propriétaires immobiliers ne pouvaient louer leurs biens au-dessus d'un certain montant. Il y avait un encadrement très rigoureux des loyers et, cet encadrement a été si rigoureux que les propriétaires ne pouvaient même plus correctement entretenir leurs biens immobiliers. La Cour européenne a considéré que cette législation violait le droit au respect des biens des propriétaires prévu par **l'article 1^{er} du 1^{er} protocole additionnel qui prévoit le droit au respect des biens**. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans cette affaire que tous les propriétaires polonais qui étaient placés dans cette situation subissaient une atteinte au droit au respect de leurs biens et donc, avaient droit à réparation. Autrement dit, elle a anticipé et neutralisé les litiges à venir, **la Cour Européenne des droits de l'Homme a régulé les contentieux**. La procédure de l'arrêt pilote entre d'une certaine manière en contradiction avec la prohibition en droit interne des arrêts de règlement prévu par **l'article 5 du code civil** qui interdit aux juges de se prononcer par voie générale et abstraite. Dans le cadre de la procédure dite des arrêts pilotes, la Cour peut reprendre l'examen des affaires ajournées si l'intérêt de la justice l'exige.

CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX DEVANT LA COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME

Ici, les étapes de l'examen de la Cour se déroulent de manière chronologique : elle doit tout d'abord examiner la recevabilité de la requête, c'est-à-dire concrètement, elle doit vérifier si les conditions posées par la Convention sont respectées. Si les conditions ne sont pas respectées, il y a un rejet de la requête. Lorsque la requête est recevable, la Cour invite les partis à parvenir à un règlement amiable et, en l'absence d'un tel règlement, la Cour procède à un examen au fond de la demande et, in fine, elle doit rendre un arrêt.

• SECTION 1 : L'EXAMEN DE LA RECEVABILITE

Les conditions relatives à la recevabilité sont posées par l'article 35 de la Convention. Il s'agit de :

- 1^{re} condition : les **voix de recours internes** doivent avoir été **épuisées**
- 2^{re} condition : **l'introduction de la requête** doit intervenir dans un **délai de 6 mois** à partir de la date de la décision interne définitive jusqu'au 1^{er} février 2022 et, après le 1^{er} février 2022, ce sera un délai de 4 mois à compter de la date de la décision interne définitive. Ceci est dû à l'entrée en vigueur du protocole n°15 du premier août 2021.

Lorsqu'il s'agit de compter un délai, on dit que ceux sont des règles de computation (fait de compter). En droit, le **1^{er} jour** lorsqu'on compte le **délai** s'appelle le « **dies a quo** » et le **dernier jour d'un délai** est appelé le « **dies ad quem** ».

La **requête ne peut pas être anonyme** et, elle **ne peut pas** être essentiellement **la même qu'une requête préalablement déposée** et **examinée** par la **Cour européenne** ou par toutes

autres instances internationales d'enquêtes ou de règlements sauf, si des faits nouveaux sont intervenus depuis lors. La requête **ne peut pas être incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles** ou encore, elle ne peut **pas** être manifestement **mal fondé ou abusive**, par exemple la situation d'un requérant qui multiplierait les recours sans raisons. Également, avant l'entrée en vigueur du protocole n°15, le 1^{er} août 2021, la Cour pouvait déclarer une requête irrecevable si le requérant n'avait pas subi un préjudice important sauf si le respect des droits de l'Homme, garanti par la Convention et ses protocoles, exigeait un examen de la requête au fond. Désormais, le critère de recevabilité de préjudice important a été modifié par les textes, c'est-à-dire que la violation du Droit doit **atteindre un niveau minimum de sévérité**, c'est-à-dire que la violation du droit ne doit pas être seulement légère. Ceci permet de rendre plus effective la protection des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles.

- SECTION 2 : LE REGLEMENT AMIABLE

Depuis l'entrée en vigueur du protocole n°11, qui est entré en vigueur le 11 novembre 1998, à tout moment de la procédure, la Cour peut procéder à la recherche d'un règlement amiable. Le règlement amiable est une procédure confidentielle permettant d'établir un accord entre les parties qui a pour but d'effacer la violation de la Convention ou de ses protocoles mais aussi, d'effacer les conséquences dommageables de cette violation. Le caractère confidentiel est justifié pour préserver et garantir les intérêts en présence, c'est-à-dire ceux de la victime mais également ceux de l'Etat signataire mis en cause. Si un tel accord est trouvé, l'affaire est rayée du rôle de la Cour par l'adoption d'une décision qui va exposer un résumé des faits ainsi que l'indication de la solution trouvée. Cette décision est ensuite transmise au comité des ministres qui a en charge de s'assurer la bonne exécution de la décision.

- SECTION 3 : L'EXAMEN AU FOND DE LA REQUÊTE

A la suite de la déclaration de recevabilité et, en l'absence d'un règlement amiable, la Cour examine le fond de la requête. Cet examen au fond l'a conduit à rendre un arrêt motivé. L'exigence de motivation permet de se prémunir contre l'arbitraire du juge car, elle oblige à justifier sa décision. Il faut savoir que l'arrêt peut parfois être accompagné des opinions dissidentes (qui vont à l'encontre) ou concordantes des juges. L'arrêt peut également parfois contenir en son sein, préciser, les mesures que doit prendre l'Etat signataire pour faire cesser la violation et donc se mettre en conformité avec la lettre de la Convention et ses protocoles additionnels.

- SECTION 4 : LES ARRÊTS DE LA COUR

Le premier arrêt de la Cour Européenne des droits de l'Homme est un arrêt « **Lawless contre Irlande** » en date du **14 novembre 1960**. Depuis, la jurisprudence de la Cour Européenne s'est densifiée mais, de manière générale, il faut préciser que l'arrêt définitif est obligatoire pour l'Etat concerné. C'est-à-dire que l'Etat dispose d'un délai de 6 mois à partir de la date de l'arrêt pour présenter un bilan des mesures prises pour exécuter l'arrêt. De la même manière, les

autres états signataires sont également concernés par les arrêts de la Cour et, ils doivent le cas échéant (si l'hypothèse se présente), mettre en conformité leur législation nationale avec l'interprétation et le sens donné par la Cour dans son arrêt. On peut dire en ce sens que les arrêts de la Cour s'imposent « erga omnes » : à l'égard de tous.

Il faut savoir que le comité des ministres est en charge de garantir la bonne exécution des arrêts et, il travaille pour se faire, en étroite collaboration avec le service de l'exécution des arrêts de la Cour Européenne des droits de l'Homme.

Depuis le **1^e juin 2010**, date de l'entrée en vigueur du **protocole n°14**, il existe une **procédure particulière en manquement** il s'agit de l'hypothèse de la non-exécution d'un arrêt de la Cour par un Etat signataire qui est mis en cause. Dans cette situation particulière, le comité des ministres peut d'abord décider d'une mise en demeure de l'Etat concerné afin qu'il se mette en conformité avec l'arrêt. Dans l'hypothèse où l'Etat reste sourd à cette mise en demeure, alors, le comité des ministres peut saisir la Cour qui va alors siéger en Grande chambre à l'occasion d'un **recours en manquement**. La décision qui est alors prise par la grande chambre doit être prise à la majorité des 2/3 des membres. Il s'agit là d'un moyen de pression qui est essentiellement politique car, il n'existe aucun moyen coercitifs (obligatoires, contraignants) pour imposer quoi que ce soit à l'Etat.

TITRE 2 : LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPENNE

Pour construire l'Europe, les états, au nombre de 27, ont conclu entre eux des traités instituant des communautés européennes puis, une Union Européenne dotée d'institutions qui adoptent des règles de Droit dans des buts déterminés en conformité avec leurs objets. Lorsqu'une institution est créée dans un but particulier, on parle d'institution « ad hoc ».

La Cour de justice de l'Union Européenne constitue la juridiction principale de l'Union. Elle est composée de 2 juridictions :

- La Cour de justice
- Le tribunal

La mission première est d'examiner la légalité, la conformité aux normes des actes et d'assurer l'interprétation des actes de l'Union.

Il y a 3 types d'avis :

- facultatif : on n'est pas obligé de le demander et pas obligé de le suivre
- obligatoire : on est obligé de le demander mais pas obligé de le suivre
- conforme

La Cour de justice et le tribunal ont pour fonction d'assurer une **interprétation conforme**, c'est-à-dire on est obligé de demander et d'appliquer, et **uniforme du Droit de l'Union**. Au fil de sa jurisprudence, la Cour de Justice a dégagé l'obligation pour les administrations et les juges nationaux d'appliquer pleinement le droit de l'union à l'intérieur de leur sphère de compétence et de protéger les droits conférés par celle-ci aux citoyens de l'Union. C'est ce que l'on appelle **l'application directe du droit de l'Union**. D'ailleurs, les administrations et les juges nationaux doivent neutraliser toutes dispositions contraires du droit national, que cette norme soit antérieure ou postérieure à la norme de l'Union. C'est le principe de la **primauté du droit de l'Union sur le droit national**.

CHAPITRE 1 : LA COUR DE JUSTICE

• SECTION 1 : L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE

La cour de justice de l'Union Européenne c'est la **CJUE**. Elle se compose d'un juge par état membre, elle comprend donc **27 juges** ayant un mandat de 6 ans renouvelable. Les juges de la Cour choisissent en leur sein un président et un vice-président, pour une période renouvelable de 3 ans. Le **président** dirige les travaux de la Cour de justice, chaque année, il y a des rapports écrit qu'il dirige ; il préside également les audiences et les délibérations des plus grandes formations de jugement. Le **vice-président** assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et, le cas échéant, il va le remplacer si c'est nécessaire. La Cour comprend

également **11 avocats généraux**, ils ont un mandat renouvelable de 6 ans, leur rôle est primordial car ils présentent, en toute **indépendance (article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne)**, des conclusions dans le cadre des affaires dont ils sont saisis. Les juges et les avocats généraux sont, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'UE, choisis car ils présentent des garanties d'indépendance et car ils réunissent les compétences juridiques nécessaires.

La **Cour de justice** peut siéger selon **3 types de formation** :

- En **Assemblée plénière**, qui est la formation la plus solennelle et qui ne peut être saisie que dans des hypothèses bien délimitées par les textes. C'est notamment le cas dans des cas déterminés, précisés par les textes. Les cas exceptionnels sont lorsque l'affaire revêt un caractère solennel.

- La **Grande chambre de 15 juges** : elle intervient pour les affaires complexes, et peut être réunie toutes les fois qu'un état parti en fait la demande.

- La **Chambre** est composée de 3 ou 5 juges et intervient dans le cadre de la plupart des affaires.

- **SECTION 2 : LES PROCEDURES**

Ici encore, devant la Cour de justice de l'Union Européenne, il existe plusieurs types procédure. En règle générale, elle prévoit toutes une **forme écrite** à laquelle peut être adjointe, agréger, par une **procédure orale publique** qui la complète. **L'écrit permet de motiver** et est donc **une garantie fondamentale de l'état de Droit**. A la fin de la phase écrite, les partis ont 3 semaines à leur disposition pour indiquer à la Cour, et motiver leur souhait d'audience de plaidoirie. Ensuite, la Cour décide de la façon dont l'affaire doit être traitée, en tenant compte de la proposition du juge rapporteur, ainsi que de l'avis de l'avocat général. Soit on peut tenir une audience de plaidoirie directement, soit, il y a besoin d'ordonner des mesures d'instructions.

PARAGRAPHE 1 : LES TYPES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR

Il existe plusieurs types de procédure devant la Cour de justice

A- LE RENVOI PREJUDICIEL

Le renvoi préjudiciel est la procédure la plus connue qui permet à la **Cour de justice de dialoguer directement avec les juridictions des états membres** car, les juridictions des états membres doivent agir en tant que juge de droit commun du droit de l'Union Européenne.

Il existe **2 types** de renvoi préjudiciel s'ouvrant aux juridictions nationales dans le cadre d'un litige principal. Le **juge saisi au principal** d'une affaire est appelé le « **juge a quo** ».

- Le **renvoi en interprétation** : est le recours par lequel, le juge national, qui est aussi « **juge a quo** », peut demander à la Cour de justice de l'Union d'interpréter une ou plusieurs

dispositions du Droit de l'Union Européenne. Cette possibilité devient même une obligation pour le juge au principal lorsqu'il statue en dernière instance, sauf circonstances particulières.

- Le **renvoi en appréciation de validité** : Le juge national, saisi au principal, va demander à la Cour de se prononcer sur la validité d'un acte du Droit de l'Union Européenne, par exemple, un règlement, une directive de l'Union.

La **Cour de justice** répond par un **arrêt** ou par une **ordonnance motivée** qui va **lier le juge au principal**. Cela signifie que le juge est tenu de suivre l'arrêt ou l'ordonnance rendu par la Cour. Non seulement, l'arrêt ou l'ordonnance motivée lie le juge au principal, mais il est également opposable, la solution dégagée doit être respectée par toutes les juridictions nationales qui se trouvent confrontées à une problématique identique. Toutes les parties présentes devant la juridiction de renvoi, peuvent directement participer à la procédure.

B- LE RECOURS EN MANQUEMENT

Le recours en manquement permet à la Cour de justice de l'UE, de **vérifier le respect des obligations découlant du droit de l'Union**, par les états membres. Ce recours peut être engagé par la commission européenne ou par un autre état membre. Cependant, il y a un formalisme à respecter. Avant de saisir la Cour, la commission doit au préalable, permettre à l'état membre concerné, de répondre aux griefs, aux allégations, qui lui sont adressés. En procédure civile interne, le principe du contradictoire doit être respecté par les juges et les parties (Article 6 paragraphe 1 de la CEDH). A la suite de cette procédure, si la Cour constate l'existence d'un manquement de la part de l'état, alors, celui-ci doit y mettre fin sans délai. On ne lui accorde pas de délai raisonnable.

Pour respecter les **exigences du délai raisonnable**, il faut distinguer entre 2 situations :

- soit les textes prévoient un délai, dans cette hypothèse il faudra, pour le Sujet de droit concerné, il faudra se mettre en conformité avec ce qui est demandé, dans les délais impartis ;
- soit le texte est muet sur ton délai, il faudra se mettre en conformité avec ce qui est demandé en fonction des difficultés particulières du contentieux et, tout particulièrement, en fonction de la complexité de l'affaire.

La complexité du dossier peut être matérielle, géographique, temporelle, personnelle.

Si l'état concerné ne met pas fin à son manquement, la **commission** peut à nouveau saisir la Cour afin que soit prononcée une **sanction pécuniaire** (argent) : il peut s'agir d'une **indemnité forfaitaire** par exemple, la condamnation de la Pologne à 50 000 euros ou bien, il peut s'agir d'une **astreinte** : on va condamner l'état à 1 million d'euros par jour tant qu'il ne se sera pas mis en conformité avec ses obligations.

C- LE RECOURS EN ANNULATION

Le recours en annulation permet à la Cour d'**annuler l'acte d'une institution, d'un organe, ou d'une administration de l'Union**. En la matière, la Cour est compétente toutes les fois qu'un tel recours est introduit par une institution de l'Union contre une autre institution de l'Union ou alors, par un état membre contre le Parlement européen et/ou, contre le Conseil de l'Union mais, cela ne vaut pas en matière d'aides étatiques ou, pour d'autre pratique tel que le dumping. Le dumping est toutes pratiques qui consistent à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national.

D- LE RECOURS EN CARENCE (obligation de faire qui n'a pas été réalisé)

Le recours en carence permet à la Cour de justice de l'UE de **vérifier la légalité de l'inaction d'une institution d'un organe ou d'un organisme de l'Union** ; après que celui-ci a été invité à agir pour mettre fin à cette carence. Si la Cour constate l'existence d'une carence, l'institution ou l'organisme doit mettre fin à celle-ci, sous peine de sanction pécuniaire.

E- LE POURVOI

Le pourvoi **permet de saisir la Cour de justice de l'UE, contre les arrêts et ordonnances du tribunal mais, seulement pour des questions de droit**. La Cour, dans cette hypothèse, examine la recevabilité et le bien fondé du pourvoi et peut décider d'annuler la décision du tribunal.

PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L'UE

Il existe un certain nombre de **procédures spécifiques** qui ont pour objet de lui permettre de statuer plus rapidement.

- **Le jugement sans les conclusions de l'avocat général**, qui permet à la Cour de rendre une décision, sans avoir véritablement, formellement, matériellement, les conclusions de l'avocat général. Cette procédure se rencontre, tout particulièrement, lorsque la question de droit posée à la Cour n'est pas nouvelle.

- **Le référé** permet d'obtenir le sursis à l'exécution d'un acte, c'est-à-dire que l'on suspend l'exécution en attendant de se prononcer sur le fond de l'affaire.

CHAPITRE 2 : LE TRIBUNAL

• SECTION 1 : L'ORGANISATION DU TRIBUNAL

Le tribunal était anciennement appelé le **Tribunal de première instance des communautés européennes** et, ce tribunal assiste la Cour de Justice depuis 1989. Le tribunal est composé de 2 juges par état membres ; ils sont choisis parmi des personnalités présentant des garanties

d'indépendance suffisantes et réunissant les conditions requises pour l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles. Leur désignation est le fruit d'un accord, d'un consensus entre les différents gouvernements des états membres. Le tribunal ne dispose pas d'avocats généraux permanents mais, cette fonction peut être exercée par l'un des juges du tribunal, de façon exceptionnelle. Lorsque l'on dit qu'une personne a une fonction exceptionnelle, en droit, cela a plusieurs conséquences. Cela signifie que le texte spécial doit être appliqué « dans toute les mesures de sa raison d'être » mais, toutes les fois où le texte spécial est muet ou obscur, c'est-à-dire peu clair, sur la situation qui se pose à nous, on doit retourner à l'application de la règle générale ; c'est ce que l'on appelle en droit, le principe de **l'interprétation stricte de tous les textes exceptionnels**. Par exemple, il existe des textes qui régissent les différents types de sociétés commerciales, comme la Société anonyme. Toutes les fois que les dispositions spéciales régissant la Société Anonyme sont muettes ou peu claires, on en revient à l'application du droit commun des sociétés et, plus précisément, à **l'article 1832 du code civil** qui dispose « le contrat de société est institué ... » il est **relatif aux éléments constitutifs du contrat de sociétés**, à savoir un apport en capital ou en industrie et, la volonté commune de s'associer. Le texte spécial s'applique dans toute la mesure de sa raison d'être et toutes les autres fois, on en revient à la règle générale.

Le **tribunal** peut **siéger** selon des formations de **jugement différentes**.

- Il peut siéger à **juge unique** mais, il faut qu'un texte spécial prévoit l'hypothèse.
- Il peut également siéger en **Chambre de 3 à 5 juges**.
- Il peut siéger en **Grande chambre de 15 juges**, qui est réunie en fonction de la complexité de l'affaire.

La **compétence du tribunal** concerne également les recours qui vont être portés à l'encontre d'acte des institutions des organes ou des organismes de l'Union mais, également, contre les actes réglementaires introduits par les personnes physiques ou morales, directement concernées par ces mesures. Il existe d'autres recours et notamment, les **recours introduits** afin de retenir la réparation des dommages découlant des institutions, organes ou organismes de l'Union.

- **SECTION 2 : LES PROCEDURES DEVANT LE TRIBUNAL**

Les procédures devant le tribunal sont régies par un règlement particulier que l'on appelle le **règlement de procédure**. Il existe deux types de procédure : une procédure de Droit commun et des procédures simplifiées. Les procédures simplifiées sont des procédures spéciales.

PARAGRAPHE 1 : LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN

La procédure de droit pénal s'articule en une phase écrite et une phase orale mais, la phase orale n'est qu'éventuelle.

(En procédure, il existe 2 types de formalités, de formalismes :

- Les **formalités exigées pour la validité**, si ces formalités ne sont pas respectées, on **risque la nullité de la procédure** ; c'est le formalisme « **ad validitatem** »

- Un formalisme qui, s'il n'est pas respecté, ne fait pas courir de risque de nullité mais, fait courir un **risque de limitation dans la jouissance de ses droits** ; c'est le formalisme « **ad probationem** ».

Il est équivalent de ne pas avoir de droit et, de ne pas pouvoir le prouver.)

L'ouverture de la procédure se fait par une requête écrite par un avocat et adressée au greffe. La partie adverse va alors disposer d'un délai de 2 mois pour faire valoir sa défense et produire un valoir en défense (idée de réciprocité : principe du contradictoire, article 6 paragraphe 1 de la CEDH, procès équitable). En règle générale, la partie demanderesse peut alors répondre au moyen d'un acte particulier qu'on appelle une **duplique**, et peut s'en suivre une triplique. Si se tient une phase orale, la phase se déroule en audience publique. Cette phase va permettre au juge de questionner directement les représentants des partis. Le juge rapporteur intervient alors, au moyen d'un rapport d'audience, dans lequel il va résumer les faits et, l'ensemble des argumentations.

PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES SPECIALES DEVANT LE TRIBUNAL

Il existe seulement 2 procédures spéciales devant le tribunal :

A- LA PROCEDURE DE REFERE

La procédure de référé : permet d'ordonner **le sursis à exécution d'un acte**, attaqué par un recours formé devant lui. La décision relative à la demande de référé est prise par le président du tribunal, statuant par ordonnance motivée, elle peut parfois être prise par un vice-président.

Il y a 3 conditions procédurales à respecter pour la demande en référé :

- le **recours au fond** ne doit **pas apparaître dépourvu de sérieux** ; il doit y avoir un fondement à la requête

- **l'urgence des mesures** doit être établie : le requérant doit faire état du préjudice grave et irréparable qui peut subir si on exécute la mesure

- il doit y avoir **pondération** : on doit trouver un équilibre entre l'intérêt général et la préservation l'intérêt des parties, il s'agit de **l'exigence de proportionnalité de la mesure**.

B- LA PROCEDURE EN ACCELERE

La procédure en accéléré permet au tribunal de **statuer rapidement sur le fond du litige**, tout particulièrement lorsque les **affaires sont très urgentes**. Le tribunal a un pouvoir souverain en matière de procédure accélérée, c'est-à-dire que la procédure accélérée peut être demandée à l'initiative de l'une des parties ou, elle peut être mise en œuvre souverainement par le tribunal.

PARTIE 2 : LES JURIDICTIONS INTERNES

Toute l'organisation juridictionnelle interne repose sur le grand **principe de séparation des autorités administratives et judiciaires**. Ce principe a été posé par une très importante loi, la **loi des 16 et 24 août 1790** qui « *interdit aux juges judiciaires de troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions* », c'est l'**article 13**. L'application de ce principe a justifié l'organisation d'une juridiction administrative, à côté de la juridiction judiciaire car, la juridiction judiciaire est incompétente pour trancher les litiges impliquant l'administration. Cette dualité de juridiction a suscité l'apparition d'une juridiction spéciale chargée de répartir, de définir les compétences des juridictions judiciaires et administratives. IL s'agit du tribunal des conflits qui est composé de tribunal des deux ordres, à savoir administratif et judiciaire. Avant de nous intéresser à l'autorité administratif, l'autorité judiciaire et le tribunal des conflits, il faut s'attarder sur le conseil constitutionnel.

TITRE 1 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

C'est une institution est de création récente car elle est née avec la Constitution de la Ve République. Elle siège au Palais royal, là où siège également le conseil d'état. Le conseil constitutionnel a été créé par le constituant de 1958 qui a tiré les leçons de l'échec du comité constitutionnel de la IVe République car, ce système imposé une révision de la constitution, préalablement à la promulgation d'une loi inconstitutionnelle.

CHAPITRE 1 : LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le conseil constitutionnel comprend normalement 9 membres avec une caractéristique essentielle : tous les membres font l'objet d'une nomination politique ; en effet, 3 sont désignés par le Président de la République, 3 sont désignés par le Président de Sénat et, 3 sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale. Le président actuel, nommé par le président de la République, est Laurent Fabius. L'article 56 de la Constitution, prévoit que sont également membres du Conseil Constitutionnel à vie, les anciens présidents de la République. Ces anciens présidents de la République ont des incompatibilités. Ceux qui poursuivent une carrière politique ne peuvent, en principe, siéger. 3 anciens présidents de la République ont, à ce jour, utilisé ce droit de retrait : Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est resté moins de 8 mois, Jacques Chirac moins de 4 ans. A côté de ces membres « à vie », il y a des membres nommés, la nomination est **un acte discrétionnaire**. C'est-à-dire que **l'acte de la nomination n'a pas à être motivé**. Il n'y a pas de conditions de diplômes. C'est là la différence avec les autres Cours constitutionnelles qui exigent bien souvent certaines qualifications. Bien souvent, les autorités chargées de leur nomination, veillent à nommer en grande partie des juristes ou encore d'anciens hauts magistrats. Des professeurs de droit ont pu y siéger, notamment **Georges Vedel**. Se pose alors la question de

l'indépendance des membres du Conseil constitutionnel (droit au procès équitable article 6, paragraphe 1). La matière de partialité peut être objectif ou subjectif. Les personnalités politiques qui sont nommés au Conseil constitutionnel ont terminés leur carrière politique. En plus, le mandat d'une durée de 9 ans est, non-renouvelable, de sorte que le membre nommé n'a pas à chercher à plaire au pouvoir politique pour espérer être reconduit dans ses fonctions. D'ailleurs, **l'article 57 de la Constitution rend incompatible la fonction de membre du conseil et celle de ministre ou de parlementaire**. Une **loi organique du 19 janvier 1995** impose une **incompatibilité avec tout mandat électoral** et tout poste de responsabilité au sein d'un **parti politique**.

CHAPITRE 2 : LES COMPETENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le conseil constitutionnel est principalement connu pour être le juge de la conformité des lois aux normes constitutionnelles. A côté du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel est doté d'autres obligations notamment consultatives.

- SECTION 1 : LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Le conseil constitutionnel n'est pas la seule juridiction à effectuer un contrôle de constitutionnalité puisque les juridictions ordinaires peuvent contrôler la conformité des décisions administratives à la Constitution. Il n'est pas non plus, la seule juridiction à contrôler les lois puisque les juridictions administratives et judiciaires sont habilitées à en contrôler la conformité par rapport aux traités internationaux (convention européennes). En revanche, le Conseil constitutionnel est la seule juridiction à pouvoir contrôler pleinement la conformité de la loi aux normes constitutionnelles.

PARAGRAPHE 1 : LES MODALITES DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

Le contrôle traditionnel des lois, dans ce cadre-là est prévu par **l'article 61 de la constitution**. C'est un **contrôle a priori**, c'est-à-dire qu'il intervient avant la promulgation de la loi et donc, il intervient avant son application ; ainsi, il présente un **caractère abstrait**. On dit souvent que ce contrôle constitue un **brevet de constitutionnalité pour la loi** mais non un brevet de validité juridique car, le **Conseil constitutionnel n'examine pas la conformité aux traités internationaux**. Le Conseil peut annuler la loi, en tout ou partie, s'il estime contraire à la constitution. Souvent, les annulations sont partielles, dans cette hypothèse, le président de la République peut promulguer la loi en la privant de ses dispositions invalidées. Le président de la République peut aussi, conformément à **l'article 10 de la constitution**, demander une nouvelle délibération au Parlement afin de modifier les dispositions censurées pour les rendre conformes à la Constitution. Enfin, dans le cas de ce contrôle a priori, le Conseil peut déclarer la loi conforme à la Constitution, sous réserve d'interprétation. Dans cette hypothèse, le recours est rejeté mais une réserve d'interprétation est posée. Cette réserve d'interprétation

peut être neutralisant, elle va neutraliser certaines dispositions de la loi, ou au contraire, constructive. Dans cette hypothèse, le Conseil donne une interprétation, une sorte de guide, que devront appliquer les autorités administratives et juridictionnelles chargées d'appliquer la loi.

A côté de ce contrôle a priori, il existe un contrôle a posteriori. Il est issu d'une révision constitutionnelle du **23 juillet 2008** qui, a inséré un **article 61-1 dans la constitution**, relatif à la QPC « *Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article* ». Schématiquement, au cours d'un procès administratif ou judiciaire (civil ou pénal), et à tout stade de celui-ci, en première instance, en appel ou en cassation ; une partie au procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une disposition législative, y compris issue d'une ordonnance, c'est-à-dire doit argumenter sur le fait que cette loi porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La juridiction saisie, juge saisie au principal : a quo, peut décider de renvoyer cette question soit au conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation, qui décideront ou non, de manière souveraine, de saisir le Conseil constitutionnel. Dans une telle hypothèse, le tribunal doit **surseoir à statuer**, il doit suspendre sa décision tant que le Conseil Constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la Constitutionnalité de la disposition législative litigieuse.

PRAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES TRAITES

L'article 54 de la constitution donne compétence au Conseil Constitutionnel pour **contrôler la constitutionnalité des traités dans les mêmes conditions que le contrôle a priori des lois**. Ce contrôle de constitutionnalité des traités peut aussi être effectué à l'occasion d'un recours contre la loi de ratification du traité. Le Conseil contrôle le contenu du traité mais, il se refuse à vérifier la procédure d'adoption de celui-ci. Si le Conseil constitutionnelle décèle, trouve des dispositions inconstitutionnelles, alors, l'article 54 de la constitution prévoit que l'autorisation de ratifier le traité ne peut intervenir qu'après une révision préalable de la Constitution. Plusieurs traités de l'Union Européenne, jugés non conformes à la Constitution, ont été adoptés après révision de la Constitution.

PARAGRAPHE 3 : QUELLES SONT LES NORMES DE REFERENCES DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Sont appelées normes de références, l'ensemble des textes auxquels le conseil constitutionnel va confronter la loi ou le traité qui lui est soumis et, avec lesquels il va contrôler sa conformité.

Il faut faire une distinction entre le contrôle a priori et a posteriori car, dans le cadre du contrôle a posteriori, toutes les normes constitutionnelles ne sont pas utilisées. Dans le cadre du control a priori des lois, il s'agit de toutes les normes constitutionnelles mais, seulement des normes constitutionnelles. En effet, **le Conseil ne contrôle pas la conformité des lois aux traités dans le cadre du contrôle a priori**. C'est une très importante décision IVG numéro 74-

54 DC du 15 janvier 1975. Également, il ne contrôle pas la conformité des lois ordinaires aux lois organique ; cela ne relève pas de sa compétence. Les normes constitutionnelles sont les articles de la Constitution, son préambule qui a plein de valeurs constitutionnelles et qui renvoie vers 3 autres textes qui sont également des normes de références, à savoir la DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la charte de l'environnement de 2004. A ces textes à valeurs constitutionnelles, il faut ajouter les principes à valeur constitutionnelle qui sont énoncés ou découverts par le conseil constitutionnels/ Il s'agit tout d'abord des Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) qui ont un fondement textuel et qui sont identifiés au cas par cas par le conseil constitutionnel. On peut mentionner par exemple le principe d'indépendance de la juridiction administratives. Il est arrivé au Conseil constitutionnel, plus exceptionnellement, d'énoncer, de trouver des principes constitutionnels, en l'absence, en dehors de toutes références textuelles. ; c'est le cas du principe de continuité des services publics dégagé en 1979 ou encore, des objectifs de valeurs constitutionnelles tel que la **sauvegarde de l'ordre public ou la protection de l'environnement**.

Pour le contrôle a posteriori qui s'exerce dans le cadre de **la QPC : 61-1 de la constitution** ; le conseil constitutionnel n'examine la conformité des dispositions législatives qu'aux seuls droits et libertés garantis par la Constitution. Il convient de faire une distinction essentielle entre les deux contrôles.

- SECTION 2 : LES AUTRES ATTRIBUTIONS

Il existe d'autres attributions du contentieux. A côté de ces attributions contentieuses, il existe également des attributions consultatives.

PARAGRAPHE 1 : LE CONTENTIEUX ELECTORAL

Le conseil constitutionnel est compétent pour trancher les contestations relatives aux élections parlementaires et présidentielle. Dans ce cadre-là ; le Conseil peut être saisi par des particuliers, il est alors soumis aux règles procédurales du code électoral.

S'agissant des élections parlementaires, le Conseil a pleine compétence, en matière d'élection législatives et sénatoriales. Ces compétences sont attribuées par **l'article 59 de la Constitution** et, sont très larges. Le conseil constitutionnel va contrôler la régularité des opérations des élections électorales. Il peut par exemple, rectifier un résultat, annuler une élection, contrôler la validité des comptes de campagnes, annuler s'il a un doute sur la sincérité des votes et les modalités des financements politique.

S'agissant de l'élection présidentielle, **l'article 58 de la Constitution** dispose que « **le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection, il examine les réclamations et proclame les résultats des scrutins** ». A cette occasion, durant l'élection présidentielle, il peut être saisi par un candidat, par un préfet ou par tout électeur ayant préalablement signalé une irrégularité au procès verbale d'un bureau de vote. Ici encore, il statue également sur les comptes de campagnes des candidats et il vérifie que le plafond légal de dépenses n'a pas été dépassé.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTENTIEUX DE LA NATURE DES NORMES

Il s'agit ici de trancher une question de compétences juridiques pour édicter la règle de Droit et ce, en fonction de la nature de cette règle. Ici, il y a un doute sur la nature législative ou réglementaire du texte.

Deux procédures sont prévues, ce sont des procédures dites de **déclassement de la loi** qui, si elles aboutissent, **permettent de dessaisir le Parlement au profit du Gouvernement**.

- la première procédure de déclassement est prévue par **l'article 41 de la Constitution** : **« le gouvernement peut s'opposer au cours de la discussion parlementaire au caractère législatif de la disposition en discussion, et saisir le Conseil Constitutionnel »**. Ici on est **avant la promulgation de la loi**. Si le Conseil constitutionnel considère que la disposition ne relève pas du domaine de la loi, article 34 de la Constitution, alors, le Parlement est dessaisi au profit du Gouvernement.
- la seconde procédure de déclassement est prévue par **l'article 37 alinéa 2** de la Constitution et, **concerne les lois déjà en vigueur**. Cette procédure de déclassement **a posteriori** permet au gouvernement de **modifier une loi en vigueur par décret**. Si le Conseil Constitutionnel a préalablement considéré que la disposition législative relève du domaine du règlement.

PARAGRAPHE 3 : LES ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de textes concernant **l'organisation de l'élection présidentielle** et, il doit être consulté préalablement à la mise en œuvre des pleins pouvoirs au président de la République ; au titre de **l'article 16** de la Constitution, c'est-à-dire **lorsque les institutions de la République, l'intégrité de son territoire, l'indépendance de la nation ou, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu**. Dans le cadre de l'exercice des pleins pouvoirs, après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le **président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, pour examiner si les conditions de mise en œuvre des pleins pouvoirs sont toujours réunies**.

TITRE 2 : LE TRIBUNAL DES CONFLITS (SOUVENT AU QCM)

Avant d'envisager l'organisation et les attributions du tribunal des conflits, il convient de donner quelques éléments et donc de préciser ce qu'est le **dualisme juridictionnel**.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE DUALISME JURIDICTIONNEL

Les tribunaux sont partagés en deux ordres : un ordre judiciaire (civil et pénal) et un ordre administratif, qui représente chacun, un ensemble hiérarchisé, avec au sommet La Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat pour l'ordre administratif.

Traditionnellement, la dualité des ordres de juridictions prend appui sur 2 textes : le premier est la **loi des 16 et 24 août 1790** et, plus précisément **l'article 13** et, le deuxième texte est le **décret du 16 Fructidor an III** qui précise que « **aux défenses itératives (répétées) sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelques espèces qu'il soit, aux peines de droit** ». Cette dualité est souvent présentée comme une traduction du principe de la séparation des pouvoirs et ce principe, a été sous sa forme moderne, élaboré par **Montesquieu** dans son ouvrage de *l'Esprit des lois* en 1748 « ***l'Homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites*** » selon certains, ces limites s'expriment en termes de séparation entre la puissance législative, la puissance exécutive et, la puissance de juger. Néanmoins, la doctrine contemporaine considère que la dualité des ordres de juridictions n'est pas nécessairement liée à la séparation des pouvoirs mais prend plutôt appui, assise, sur des considérations pratiques car le législateur a estimé que le règlement du contentieux administratif devait être confié à l'administration elle-même et non à des juges judiciaires. Ce système est désigné sous le nom de « **justice retenue** » car, l'administration était juge de ses actes ; c'est une **loi du 24 mai 1872** qui a conféré à des juridictions spéciales, sous entendues spécialement créées pour, les juridictions administratives ; **elle a donné compétence autonome à ces juridictions administratives pour juger les actes de l'administration**, ce qu'on a désigné sous le nom de « **justice déléguée** ». Cette **loi du 24 mai 1872 est à l'origine de la création de l'ordre administratif**.

De nos jours la dualité des juridictions est essentiellement justifiée par la particularité du droit administratif qui nécessite des juges spécialisés pour trancher les litiges de l'administration. Le principe du **dualisme juridictionnel** amène une **valeur constitutionnelle** car, le Conseil constitutionnel considère que le **principe selon lequel il relève de la compétence de la juridiction administrative de statuer sur l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif**. Ce principe est un principe fondamental Reconnu par les lois de la République PFRLR, selon le Conseil Constitutionnel, depuis 2 décisions du Conseil constitutionnel :

- 86-224 du 23 janvier 1987
- 89-261 du 28 juillet 1989

La dualité des juridictions est un PFRLR

La Cour Européenne a dans **l'arrêt important SACILOR-LORMINE-contre France**, en date du 9 novembre 2006, a considéré la position originale du conseil d'Etat français parmi les institutions françaises car, il peut être directement impliqué à l'exercice du pouvoir. En effet, le Conseil d'Etat est parfois appelé à exercer une fonction consultative et, à ce titre, il peut émettre des avis. La Cour Européenne a cependant noté que cette situation ne suffit pas à caractériser un manque d'indépendance du Conseil d'état car, la principale raison est que les juridictions administratives sont soumises au respect des exigences du procès équitables et donc aux garanties posées par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne.

CHAPITRE 1 : L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS

Le tribunal des conflits est apparu pour la première fois sous la II^e République mais, il a été véritablement et définitivement établie par une très importante loi du **24 mai 1872**. Le tribunal est conflit **siège au conseil d'Etat au Palais-Royal**. L'organisation du tribunal des conflits est marquée par la parité : il est composé de 4 magistrats du siège de la Cour de cassation et de 4 membres du Conseil d'Etat élus pour une durée de 3 ans. Un juge n'est rééligible que 2 fois. A ces 8 membres, s'ajoutent 2 suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les textes nous disent que le tribunal ne peut valablement siéger que si, **au moins 5 de ses membres** sont présents. En outre, il existe 2 rapporteurs publics issus du Conseil d'Etat et, 2 autres qui sont issus du Parquet Général près (on ne dit pas auprès de la cour mais près) la Cour de cassation. Ces rapporteurs doivent exposer publiquement et en toute indépendance leurs opinions sur les questions que présentent à juger les affaires dont le tribunal est saisi. Jusqu'à la loi très importante du **16 février 2015**, le tribunal des conflits était **présidé par le ministre de la Justice**. Désormais, la présidence est alternativement assurée tous les 3 ans par **un magistrat judiciaire** (membre de la Cour de cassation) puis, par le **président du conseil d'état**, président qui est élu. Lorsqu'une affaire est ouverte devant le tribunal des conflits, elle est confiée à un rapporteur et à un rapporteur public ; chacun relevant d'un ordre de juridiction différent. A l'issue de l'instruction de l'affaire, une audience publique est tenue, au cours de laquelle les avocats des partis (avocat aux conseils qui sont habilités), peuvent présenter des observations. La représentation par un avocat aux conseils est obligatoire, par exemple : François Briard. Lors de l'audience, le rapporteur lit son rapport, puis, le rapporteur public qui appartient à l'autre ordre de juridiction va prononcer ses conclusions. Depuis 2015, le ministre de la Justice n'a plus le pouvoir de départager les lois. C'est pourquoi, en cas de partage égal des voies il y a une seconde délibération. Si, après la seconde délibération, il y a encore partage égal des voies, on instaure une formation élargie avec 4 juges supplémentaires, 2 issus du Conseil d'Etat, 2 issus de la Cour de cassation mais, en pareille hypothèse, il faut savoir que le tribunal des conflits ne pourra alors valablement délibérer que si tous les membres sont présents. Il est impossible d'arriver à égale délibération, cela est possible mais ne s'est jamais réalisé.

CHAPITRE 2 : LE TRAITEMENT DES CONFLITS

Les difficultés d'attribution de compétences entre les 2 ordres de juridictions sont relativement rares. En effet, en moyenne, le tribunal des conflits ne rend qu'une quarantaine de décision par an, lorsque le juge administratif et le juge judiciaire sont en conflits, en contradiction, en désaccord pour déterminer la compétence juridictionnelle. Schématiquement, 2 hypothèses peuvent se présenter. Face à un litige donné, le juge judiciaire et le juge administratif, peuvent tous les deux reconnaître leur compétence. On

parle alors de **conflit positif**. A contrario, le juge judiciaire et le juge administratif peuvent rejeter leur compétence, on parle alors de **conflit négatif**.

- SECTION 1 : LE CONFLIT POSITIF

Le conflit positif se présente lorsqu'un **procès est engagé devant le juge judiciaire et que l'administration souhaite que le litige relève de la compétence du juge administratif**. La configuration inverse n'existe pas, c'est-à-dire lorsque se tient un procès devant le juge administratif, le juge judiciaire ne dispose d'aucun moyen pour faire valoir sa compétence. Dans un conflit positif, l'autorité administrative mise en cause devant le juge judiciaire peut solliciter le préfet pour qu'il adresse à la juridiction saisie un **déclinatoire de compétence**. Cet acte peut intervenir à tout moment du procès, il doit être **motivé** c'est-à-dire que le préfet doit, dans le déclinatoire indiquer les motifs qui justifient la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire doit statuer sur cette demande après audition du ministère public. Soit le juge judiciaire s'incline et se déclare incompétent au profit du Juge administratif, soit le juge judiciaire n'est pas convaincu par le déclinatoire de compétence et il refuse de se dessaisir. Dans une telle hypothèse, il appartient alors au préfet dans un délai de 15 jours, de prendre un **arrêté de conflit** qui doit être motivé. L'arrêté de conflit est un acte procédural très important puisqu'il permet de saisir le tribunal des conflits et, lorsque le tribunal des conflits est saisi, le juge judiciaire doit s'abstenir de statuer, il doit **surseoir à statuer** tant que le tribunal des conflits n'a pas rendu son arrêt. **Le tribunal des conflits a 3 mois pour rendre son arrêt**. Là encore, 2 hypothèses peuvent se présenter : le tribunal des conflits peut, soit annuler l'arrêté de conflit et confirmer ainsi la compétence du juge judiciaire ; soit, il peut confirmer l'arrêté de conflit et, dans une telle hypothèse, le requérant doit alors saisir le juge administratif.

- SECTION 2 : LE CONFLIT NEGATIF

Il est inélégant de parler de conflit négatif, il s'agit plutôt d'un **conflit sur renvoi**. Il y a conflit négatif lorsque le justiciable saisit successivement les 2 ordres de juridictions et que, chacun des deux ordres se déclarent incompétent au profit de l'autre. Jusqu'en 1960, le justiciable, dans cette hypothèse, devait saisir le tribunal des conflits qui statuer alors sur la compétence de l'un ou de l'autre ordre, annulant l'un des deux jugements. Il appartenait ensuite au justiciable de saisir la juridiction désignée comme compétente. Un décret du **25 juillet 1960** est venu raccourcir la procédure et, a **mis en place le conflit sur renvoi**. Ainsi, lorsque le justiciable fait face à un premier jugement d'incompétence, il doit toujours saisir l'autre ordre de juridiction mais, si cet autre ordre de juridiction se déclare aussi incompétent, il appartient à cette dernière juridiction de saisir le tribunal des conflits, c'est ce qu'on appelle le conflit sur renvoi. **Depuis 1960, le tribunal des conflits, dans cette hypothèse, est saisi par une juridiction et non par un justiciable**. Une fois saisi, le tribunal des conflits se prononce après une procédure contradictoire et, c'est lui qui doit saisir la juridiction compétente. Si le juge désigné est le juge judiciaire alors, le préfet ne pourra pas intervenir. En 2015, le législateur a

institué une procédure de prévention en la matière, il offre la possibilité aux juridictions qui font face à un problème de compétence de saisir directement le tribunal des conflits afin de gagner du temps.

CHAPITRE 3 : LES ATTRIBUTIONS AU FOND

Depuis une très ancienne **loi du 20 avril 1932**, le tribunal des conflits peut, exceptionnellement, statuer sur le fond d'un litige saisi par un justiciable et, c'est le cas lorsque le juge administratif et le juge judiciaire ont tous les deux statué au fond mais de façons divergentes. Dans une telle hypothèse, le tribunal des conflits peut annuler ou réformer les décisions rendues au fond et, y substituer sa propre décision. Cette procédure porte le nom de **conflit de décision**. Depuis **2015**, le tribunal des conflits bénéficie d'une seconde attribution au fond, c'est l'hypothèse dans laquelle la durée excessive de la procédure juridictionnelle a causé un dommage au justiciable, c'est-à-dire qu'il y a eu violation des exigences du **délai raisonnable posé par l'article 6 paragraphe 1** de la **CEDH** : Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'Etat est responsable de ce dommage et, si la durée excessive est liée au dualisme juridictionnel alors, le tribunal des conflits est compétent pour statuer sur le montant de la réparation, après une réclamation infructueuse portée devant le ministre de la Justice.

TITRE 3 : LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

La juridiction judiciaire comprend à la fois les juridictions civiles et les juridictions pénales ou répressives. De manière générale, elle fait application du droit privé, en principe entre personnes privées mais, la juridiction judiciaire peut connaître des litiges entre personnes privées et l'Etat. Les personnes publiques sont ainsi susceptibles d'être poursuivies sur un plan pénal. Cela est vrai depuis la loi Fauchon, l'article 121-3 du code pénal.

Le principe du double degré de juridiction implique que le justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue une nouvelle fois par une juridiction hiérarchiquement supérieure s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance. En première instance, la décision rendue prend bien souvent le nom de jugement (ordonnance si un seul juge), en appel, il s'agit d'un arrêt. Il ne faut pas confondre avec l'arrêté qui lui, est une décision administrative qui n'est pas de nature juridictionnelle.

CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS CIVILES DU PREMIER DEGRE

Traditionnellement, le **contentieux civil** relève, en principe des **tribunaux judiciaires départementaux** mais, certains **contentieux élevés** relèvent des **juridictions d'exception**.

- SECTION 1 : LES JURIDICTIONS CIVILES DE DROIT COMMUN

Initialement, c'est par une loi des **16 et 24 août 1790**, que le législateur a institué les **tribunaux de districts**, au nombre de **545**. Par une **ordonnance du 22 décembre 1958**, ces juridictions sont modernisées et leur nombre est réduit, on dénombre alors **181 tribunaux de grande instance**. La réforme de la **carte judiciaire** est entrée en vigueur le 1^e janvier 2011, a considérablement réduit les tribunaux de Grande Instance puisqu'ils sont passés à **158** et, par cette même réforme, on est passé de 472 tribunaux d'instance à 297. La **loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice** a procédé à la fusion des tribunaux de grandes instances et des tribunaux d'instance que l'on appelle désormais les tribunaux judiciaires départementaux

PARAGRAPHE 1 : L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DEPARTEMENTAUX

La règle posée pour le maillage territorial est qu'il existe **1 tribunal judiciaire par département** mais, parfois, pour les départements les plus peuplés, il peut exister plusieurs tribunaux judiciaires par département et, c'est ainsi que dans le département du Nord, il existe 6 tribunaux judiciaires. Les tribunaux judiciaires comprennent au moins 3 juges, tous professionnels, 3 car ils sont appelés à statuer en formation collégiale. La plupart de ces tribunaux judiciaires sont divisés en chambres de 3 juges, chacune présidée par un magistrat, assisté d'un greffier. Bien souvent, ces chambres sont spécialisées par matière. Par exemple, le tribunal judiciaire de Paris compte 32 chambres.

A la tête du tribunal, il y a un président et, ce **président** jouit de compétences propres. Il est compétent en matière **d'ordonnance sur requête**, c'est-à-dire, qu'à la demande d'un justiciable, il va autoriser une saisie conservatoire, par exemple pour conserver des preuves, la saisie d'un ordinateur. Il peut également autoriser à un huissier à faire un constat sur une propriété privée. Ces ordonnances sur requête ne sont pas soumises au respect des exigences du contradictoire. Le président du tribunal est compétent en matière **d'ordonnance de référé**. Il s'agit de **procédures d'urgence**, permettant au juge de « **prévenir des dommages imminents ou de faire cesser une situation illicite** ». Le fondement des ordonnances de référé sont les **articles 808 et 809 du code de procédure civile**, il s'agit des fondements de droit commun mais, à côté du code commun, il existe des procédures particulières, par exemple, en matière **d'atteinte à la vie privée** et, le président va également sur le fondement de **l'article 9**. Il s'agit par exemple de la possibilité pour celui qui s'estime victime d'une atteinte à sa vie privée, d'éviter la publication de l'ouvrage qui va paraître.

Au sein du tribunal judiciaire, certains magistrats sont désignés pour exercer des fonctions spécialisées. La particularité de ces **magistrats ad hoc** est qu'ils **statuent à juge unique**. Il en est ainsi de la mise en état : le juge a pour fonction de suivre l'instruction des affaires civiles (pas pénales), afin qu'elles soient en état d'être jugées dans un délai raisonnable.

Il y a également le juge aux affaires familiales qui a pour fonction de régler les divorces, de fixer les obligations alimentaires ou encore, en matière de changement de régime matrimonial.

- Il existe également le **juge de l'expropriation** qui statue lui aussi à juge unique. Il a pour fonction de **fixer les indemnités que l'on va attribuer au propriétaire exproprié**.

- Il y a ensuite le **juge de l'exécution** qui a en charge **l'exécution des décisions de justice**.

- Il y a enfin le **juge des contentieux de la protection** qui est compétent en matière de **crédit, d'incapacité** ou de **surendettement** des particuliers.

Au sein de chaque tribunal judiciaire, il y a 1 procureur de la République et un certain nombre de substituts du procureur qui forment le ministère public ou le parquet. L'intervention du ministère public peut être systématique, par exemple en matière correctionnelle, en matière de jugement de délits mais ; elle est facultative en matière civile à l'exception de l'état des personnes. Le ministère public a la charge de représenter les intérêts de la société. Le greffier du tribunal assure les fonctions du secrétaire de la juridiction

PARAGRAPHE 2 : LES COMPETENCES DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DEPARTEMENTAUX

Le tribunal judiciaire départemental est la juridiction de droit commun en matière civile. En l'absence de disposition particulière attribuant le jugement de certains litiges à d'autres juridictions, tous les litiges restants lui sont soumis. Les compétences qui lui sont attribuées par la loi, par les **articles l211-4 et suivants du code de l'organisation judiciaire**, ne sont pas limitatives. Ainsi, le tribunal judiciaire départemental est compétent pour traiter des affaires relatives à l'état des personnes, à la propriété immobilière, aux baux commerciaux, aux redressements et la liquidation judiciaire des professions libérales, pour certains litiges fiscaux tels que ceux des droits de douane ou encore, pour tous les problèmes relatifs aux frais de justice, notamment les frais d'avocats. Le code de l'organisation judiciaire donne pleine compétence à ces tribunaux pour toutes les actions en réparation d'un dommage corporel ou encore, pour les actions de groupe qui sont définis par le code de la consommation. L'action de groupe permet aux consommateurs de se regrouper pour obtenir en justice la réparation des préjudices patrimoniaux qu'ils subissent à l'occasion des contrats de consommation. Cette compétence du tribunal judiciaire départemental s'agissant des **actions de groupe** est prévue par le code de l'organisation judiciaire : **l'article l211-9-2 du code de l'organisation judiciaire**. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires par département, certains peuvent se voir attribuer la totalité des contentieux liés à un domaine particulier. C'est une **logique de spécialisation**. D'ailleurs, certaines matières sont attribuées à certains tribunaux judiciaires : il en est ainsi de la propriété littéraire ou artistique ou encore des contentieux liés à la sécurité

sociale. **S'il n'existe pas de tribunal de commerce** dans le ressort territorial, c'est le **tribunal judiciaire qui juge les litiges** qui relèvent normalement de la compétence du tribunal de commerce : c'est l'**article 1721-2 du code de commerce**.

PARAGRAPHE 3 : LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DEPARTEMENTAUX

Le tribunal statue normalement en **formation collégiale impaire de 3 juges** mais, de plus en plus souvent, les formations uniques sont privilégiées. Dans certains domaines, on privilégie le juge unique, il en est ainsi le cas en matière d'accident de la circulation. En pareil hypothèse, dans ces domaines qui ne relèvent pas normalement du juge unique, il reste possible pour le juge, de renvoyer à une formation collégiale et, ce renvoi peut aussi être effectué à la demande des parties. En matière civile, la **représentation par avocat** est en principe **obligatoire** devant les tribunaux judiciaires départementaux. Les jugements rendus sont **susceptibles d'appels** devant la Cour d'appel **sauf**, lorsque l'enjeu du litige est **inférieur à 4000€**. Dans une telle hypothèse, le tribunal judiciaire est **juge en premier et dernier ressort**, néanmoins, un **pourvoi en cassation** reste **possible**. Le **président du tribunal** est un organe départiteur, c'est lui qui répartit les affaires entre les chambres. Il a même une fonction de notation des membres de sa juridiction ; cela peut être utile pour l'avancement.

PARAGRAPHE 4 : LES CHAMBRES DE PROXIMITE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DEPARTEMENTAUX

Ceci fait écho à une justice qui a été instaurée en **1790 : la justice de paix** qui a été instituée dans chaque canton. Jusqu'en 1926, pour ces affaires à l'enjeu relatif, de moindre importance, aucune formation en droit était exigée pour les juges de paix. C'est palabrer : avoir une discussion jusqu'à trouver une solution. Une ordonnance du 22 décembre 1958 a profondément transformé les juges de paix, ils sont devenus les tribunaux d'instance. Leur nombre a été considérablement réduit. Les **tribunaux d'instance** sont dédiés aux petites affaires civiles, c'est-à-dire, aux affaires dont le seuil n'excède pas **10 000€**. Lorsque la demande de dommages et intérêts est inférieure à cette somme, c'était le tribunal d'instance et non le tribunal de grande instance qui était compétent à l'époque. Depuis **2020**, les tribunaux d'instance et de grandes instances ont **fusionnés** pour devenir les tribunaux judiciaires départementaux. Dans les villes où il siège en **TI et un TGI**, il s'agit d'une **fusion** pure et simple mais, dans les villes-villages dans lesquelles il y a **seulement les tribunaux d'instance**, on a alors créé les **chambres de proximité**, que l'on appelle les **tribunaux de proximité**.

Au sein du tribunal de proximité, est créé un juge des contentieux et de la protection qui reprend une bonne partie des compétences qui étaient normalement dévolues aux tribunaux d'instance. Il s'agit de la tutelle des personnes, du surendettement des particuliers, des contentieux liés aux baux d'habitation ou encore des contentieux liés à l'expulsion. L'**expulsion** c'est l'**occupation sans droit ni titre valable**, d'un espace, d'un pays, d'un locataire etc. Devant les tribunaux de proximité, le seuil des 10 000€ a disparu. Le président du tribunal judiciaire est également président des chambres de proximité de sorte qu'elles ont perdu en

autonomie. La représentation par avocat, en matière civile, n'est pas obligatoire devant les chambres de proximité du tribunal judiciaire ; c'est une survivance des juridictions de paix.

- SECTION 2 : LES JURIDICTIONS CIVILES SPECIALES

On parle également, s'agissant des juridictions civiles spéciales, des **juridictions d'exceptions**. Ces **juridictions ont des compétences spécialisées** par rapport à celles du tribunal judiciaire départemental. **Certaines** ont été **supprimées** car leur compétence a été transféré au tribunal judiciaire départemental. Il en est ainsi du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (**TASS**) au **1^e janvier 2019**.

L'autre particularité de ces **juridictions spéciales** est, d'être composées de **juges non-professionnels**. Lorsqu'une **formation de jugement** comporte tout à la fois des **juges professionnels et non-professionnels**, on parle **d'échevinage**. (*Obitare dictum* : soit dit en passant).

PARAGRAPHE 1 : LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Les conseils de **prud'hommes** ont été **créés** par une **loi du 18 mars 1806**, une autre **loi du 18 janvier 1979 impose** la tenue/la **présence d'un conseil de prud'hommes** par ressort territorial du tribunal de grande instance. Certains ont été supprimés par la **réforme** de la « **carte judiciaire** » par Rachida Dati. Les dispositions relatives au conseil des prud'hommes ne se trouvent pas dans le code de l'organisation judiciaire mais, figure dans le **code du travail**, plus précisément au livre 4 de la 1^e partie. La mission première et fondamentale des conseils de prud'hommes est **de trancher les litiges individuels nés de l'existence contrat de travail**, c'est l'article **l1411-1 du code du travail**. Il y a deux types de relations du travail : individuelles (vous et le directeur), collective (un groupe).

A. L'ORGANISATION DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES

Les **juges des conseils des prud'hommes** sont appelés des **conseillers**. Ils sont pour moitié des conseillers **employeurs** et pour moitié des conseillers **salariés**. Depuis **2018**, ces conseillers ne sont plus élus mais, ils sont **désignés** par le **ministre de la Justice** sur proposition des **organisations syndicales ouvrières et patronales**, en fonction de leur audience respective (ouvrières : FO, CGT, Lutte ouvrière / patronales : CFDT, MEDEF). Ces conseillers bénéficient d'une **courte formation** mais sans commune mesure avec les juges professionnels (quelques jours seulement).

Chaque conseil de prud'hommes est divisé en **5 sections** d'au moins **6 conseillers**. Il y a une section : **encadrement, commerce et services commerciaux, industrie, agriculture, activité diverse** (tous les employés de maison, les gardiens d'immeuble etc.). Chaque section peut être subdivisée en **chambre**. Une assemblée générale des conseillers va élire un président pour une durée d'un an avec crossover obligatoire, il s'agit tantôt d'un employeur, tantôt d'un

employé. Il y a nécessairement une rotation entre les présidents. Les juges des prud'hommes ne le sont pas à plein temps, ils conservent leur activité professionnelle. Il y a des **risques de conflits d'intérêts** et de **partialité**. S'agissant des juges employés, ils bénéficient d'une protection particulière contre le licenciement. Leur licenciement n'est possible qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'employeur doit les laisser exercer leur mission en leur versant leur traitement/le salaire normalement mais, l'Etat en rembourse une partie. Pour les juges employeurs, ils ont droit à une indemnisation de l'Etat.

B. LES COMPETENCES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des **litiges individuels nés d'un contrat de travail** ou pour connaître des **difficultés liées à l'absence d'un contrat de travail**. Dans une telle hypothèse, le conseil des prud'hommes devra se prononcer a priori sur l'existence de ce contrat, c'est à dire sur **l'existence d'un lien de subordination**. Le conseil des prud'hommes est également compétent pour tous les **litiges entre salariés** qui surviennent à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. C'est le cas pour les problèmes d'harcèlement entre salariés etc. Les litiges peuvent donc porter sur la conclusion, l'exécution ou encore les modes de rupture du contrat de travail. Il est donc exclusivement compétent pour les litiges qui trouvent leur **fondement dans le contrat de travail**. Le **conseil des prud'hommes** n'est donc **pas compétent** pour les litiges concernant les **fonctionnaires** qui ne sont pas liés à leur employeur par un contrat mais par un statut.

Il existe **3 statuts** pour les fonctionnaires :

- La fonction publique **territoriale** (maires, conseillers territoriaux)
- La fonction publique **étatique** (professeur des universités)
- La fonction publique **hospitalière**

Les **litiges** concernant les **fonctionnaires** relèvent du **tribunal administratif**. Néanmoins, certains agents des collectivités territoriales relèvent de la compétence des conseils des prud'hommes. Il en est ainsi des salariés des **EPIC**, les Etablissement Publics à caractère Industriel et Commercial ou les agents de l'office des forêts. Les agents des EPIC relèvent donc de la compétence des conseils des prud'hommes. **Echappent** également à la compétence des tribunaux des prud'hommes, les **litiges collectifs de travail** (grève) ou encore les **accidents professionnels ou les maladies professionnelles**. D'une manière générale, le conseil des prud'hommes compétent est celui situé dans le ressort territorial dans lequel se trouve l'établissement où travail le salarié.

C- LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES

Les formations du conseil des prud'hommes sont en principe **paritaire**. Il existe une instance préalable qui est le **bureau conciliation et de l'orientation**, il est composé d'un employeur et d'un employé. Sa mission première est d'essayer de trouver un **accord amiable**.

Il a aussi pour fonction d'orienter le litige soit

- devant la **formation normale** : elle est composée de **2 juges employeurs et de 2 juges salariés**. En raison du principe de parité, le président n'a pas voix prépondérante, toutes les voies sont équivalentes, se valent. Pour les litiges les plus simples, la formation peut même se réunir avec un seul juge employeurs et un seul juge salarié. La formation de référé est également composée d'un juge employeur et d'un juge salarié, en vertu du principe de parité. Par exception, **lorsque les formations paritaires ne parviennent pas à trancher** le litige, il est fait appel à **un juge professionnel** du tribunal judiciaire, que l'on appelle le **juge départiteur**. Celui-ci est désigné par le président du tribunal judiciaire aux vues de ses compétences particulières. Il y a alors **échevinage**. Les parties peuvent être **assistées**, sans obligation, par leur avocat, par leur conjoint, par un salarié ou par un employeur exerçant dans la même branche d'activité. Si l'objet du litige est **inférieur à 4 000€**, le conseil des prud'hommes **statue en premier et dernier ressort**, un **pourvoi** reste possible devant la **chambre sociale de la Cour de cassation**. Si l'objet du litige est supérieur à 4 000€, l'appel reste possible devant la Cour d'appel territoriale compétente.
- Soit devant la **formation restreinte** du bureau de jugement.

PARAGRAPHE 2 : LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Pour les tribunaux de commerce, on parle également de **juridictions consulaires**. Elles sont apparues au Moyen-Age, à l'occasion des grandes foires. Les juges, à cette époque, étaient élus par les commerçants et, c'est pour cette raison qu'ils ont survécus à la période révolutionnaire. En effet, les **juridictions consulaires** ont été **épargnées lors de la révolution** alors que les révolutionnaires avaient à cœur de supprimer les corporations, c'était la loi **Le Chapelier** ou encore, le **décret d'Allarde**.

A. L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Le nombre des tribunaux de commerce était en **1998 de 227** et, il a fortement réduit, on en dénombre aujourd'hui **134**. Les tribunaux de commerce sont composés de juges commerçants, il peut s'agir de conjoints collaborateurs ou de dirigeants de société commerciale, élus par leurs paires ; c'est l'article 1721-1 du code de commerce. Les juges sont **élus pour 4 ans** et sont **rééligible** pour une durée maximale de **14 ans**. Le **premier mandat** est limité à **2 ans**.

Il s'agit d'une **élection** en 2 étapes :

- Les **commerçants élisent** les **membres** d'une **Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)** et, élisent des **délégués consulaires**.
- Ces **délégués** et ces **membres** vont **élire** les **juges consulaires**.

La particularité pour **l'Alsace et la Moselle**, c'est qu'un magistrat professionnel est associé au juge élu. On reproche à ce système un certain **corporatisme**, un entre-soi, qui pourrait porter atteinte au principe d'indépendance des juges. La profession reste très attachée à ce système

mais, elle met ultimement en évidence que l'appel relève des cours d'appel et donc, de magistrats professionnels.

Sont éligibles les commerçants âgés **d'au moins 30 ans** et, étant **inscrits au registre du commerce**.

Les juges du tribunal élisent leur **président pour 4 ans**, celui-ci n'est pas rééligible. Les fonctions de juge du tribunal de commerce sont bénévoles : non rémunérées. Une **loi du 18 novembre 2016**, prévoit pour ces magistrats des **contraintes et des garanties**, visant à assurer leur indépendance et leur impartialité. Ainsi, lors de leur prise de fonction, ces magistrats dressent une **déclaration complète de leurs intérêts** afin d'éviter, ou à tout le moins de faire cesser les conflits d'intérêts.

B. LES COMPETENCES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Les **tribunaux de commerce** sont compétents pour **régler tous les contentieux commerciaux**. Il s'agit d'abord des litiges entre commerçants, mais également des litiges entre non-commerçants, dès lors qu'est en cause un acte de commerce. La compétence des tribunaux de commerce a récemment été étendue aux artisans, la liste des actes de commerce figure à **l'article 1110-1 du code de commerce**, il s'agit des **actes de commerce par nature**, par exemple achat pour revente ; il s'agit des actes de **commerces par accessoire**, un **acte de commerce par la forme**, **acte des sociétés commerciales**. Relèvent également du tribunal de commerce, les **litiges avec les établissements de crédits** ainsi que les **procédures collectives**, c'est-à-dire le redressement et la liquidation judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce n'est cependant pas compétent pour les litiges relatifs aux baux commerciaux (car relèvent du tribunal judiciaire), ou encore pour les litiges qui apparaissent entre un commerçant et un agriculteur pour la vente de denrée alimentaire.

C. LE FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Le président du tribunal de commerce dispose **d'attributions** qui lui sont **propres**, notamment les **ordonnances sur requête** ou encore les **ordonnances de référé**, par exemple pour désigner un expert. Il dispose des attributions en **matière disciplinaire**. Le tribunal de commerce est divisé en chambre et, par principe, statut en formation collégiale impaire de 3 juges. Le procureur du tribunal judiciaire peut toujours décider d'intervenir à l'audience et, un juge est nommé pour instruire l'affaire et, lorsqu'il considère que l'affaire est en état d'être jugé, il la renvoie au tribunal. A l'audience, ce magistrat peut faire un rapport oral, dans lequel il va exposer l'objet de la demande, les moyens des parties, et, il va faire état des questions de faits et de droits posées par l'affaire. Néanmoins, en aucun cas, ce juge ne doit exprimer son opinion sur le dossier à juger. Viennent ensuite les plaidoiries des parties et, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal de commerce. Les jugements rendus par les tribunaux de commerce sont **insusceptibles d'appel**, ils sont rendus en premier et dernier ressort, lorsque le montant du litige est **inférieur à 4 000€**, un recours en cassation reste possible. Au-delà de 4 000€, un appel est susceptible d'être formé. Le **greffier du tribunal** n'est pas un fonctionnaire mais un **officier public ministériel**, il doit prendre note des débats. Il tient le registre et délivre les jugements et, enfin, il tient le registre du commerce et des sociétés, qui est le registre d'état civil des sociétés.

PARAGRAPHE 3 : LES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Ces tribunaux ont été créés sous le **régime de Vichy** dans une logique corporatiste et, elles ont été sérieusement réformées à la Libération et, notamment par un décret du 22 décembre 1958. Les tribunaux paritaires des baux ruraux ont une existence qui résultent de la spécificité du bail rural conclut entre le propriétaire et le fermier. **Le fermier c'est le locataire d'un bail rural**. La particularité des baux ruraux est leur **nature mixte**, c'est-à-dire que leur régime **emprunte** toute à la fois le **bail traditionnel**, au **bail classique** et au **contrat de travail**.

A. L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Il existe un TPBR par **ressort de tribunal de proximité**, soit actuellement **307**. L'**échevinage** est appliqué aux TPBR. En effet, ceux-ci sont présidés par un juge professionnel du tribunal de proximité et les assesseurs sont cependant des juges non-professionnels. Ils ont été longtemps élus mais, depuis le **1^{er} janvier 2018**, ils sont **désignés** par le premier président de la Cour d'appel, après avis du **président du tribunal paritaire des baux ruraux** qui consulte une **liste établie par le préfet**, c'est l'article l492-2 du code rural. Les TPBR ne sont **pas organisés en chambre mais en sections**. Il y a toute à la fois la section des **baux à ferme** et la section des **baux à métayage**. Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à **bail à un preneur à bail (celui qui profite du bail)**, qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en **partager les produits avec le bailleur**. En principe aujourd'hui, ce contrat est très peu usité.

B. LES COMPETENCES DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Le tribunal compétent est celui dans le **ressort territorial** duquel se **trouve le bien en litige**. On applique ici une règle traditionnelle du **code de procédure civile**, suivant laquelle est compétent le **tribunal du lieu de situation de l'immeuble**, à savoir la *lex rei sitae*.

C. LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Les tribunaux paritaires des baux ruraux ont une **activité assez réduite**, c'est pourquoi ils ne siègent pas de façon permanente mais par **session**. La formation de jugement est en principe de **5 juges** : 1 juge professionnel, 2 juges non professionnels représentant les bailleurs, 2 juges non-professionnel représentant les preneurs. Le président du tribunal dispose de compétences qui lui sont propres, il est ainsi **juge des référés** et, peut parfois **statuer seul au fond**, lorsqu'il lui est impossible de réunir l'information de jugement mais, il lui faut au préalable, qu'il obtienne l'accord des assesseurs. Le TPBR rend des **jugements en premier et dernier ressort** lorsque l'enjeu du litige est **inférieur à 4000€** dans une telle hypothèse, un recours en cassation reste possible. Si l'enjeu du litige est **supérieur à 4000€**, alors le tribunal est tout simplement **juge en premier ressort, un appel est possible**.

CHAPITRE 2 : LES JURIDICTIONS PENALES

Les juridictions pénales **orientent et conditionnent le procès pénal**. Au sens large du terme, le procès pénal peut être défini comme **le tarif que la société**, en temps donné, **à un trouble porté à la paix sociale**. Tout le droit pénal gravite autour d'un principe : **le principe de la**

légalité des délits et des peines que l'ont dû à **Beccaria** qui l'a exposé dans son ouvrage Traité des délits et des peines. Il résumait le principe de légalité des délits et des peines par une formule : « **aucun crime, aucune peine sans texte préalable** » soit : « **Nullum crimen, nulla poena, sine lege** ». Ce principe de légalité des délits et des peines, suppose que l'on ne peut être poursuivi ou condamné au pénal, s'il n'existe pas d'incrimination. **L'incrimination** se définit comme **le texte législatif ou réglementaire qui prévoit** à la fois les **éléments constitutifs de l'infraction et, la peine** que l'on risque. S'agissant de la peine que l'on risque, on parle de « **quantum** » de la peine, c'est le **seuil**.

Le principe de légalité des délits et des peines à plusieurs conséquences :

- **L'interprétation stricte** des textes et de la loi pénale
- La **non-rétroactivité** de la loi pénale **sauf lorsque la peine encourue est plus douce**, dans ce cas là on parle de **rétroactivité** « **in mitius** ».
- « **Non bis in idem** » : pas 2 fois sur la même chose. A partir du moment où vous êtes condamné, avez été reconnu coupable, on ne peut **pas être jugé ultérieurement pour les mêmes faits**.

Comme pour toutes les juridictions, il y a lieu de distinguer les juridictions de droit commun et les juridictions spéciales (ad hoc).

- **SECTION 1 : LES JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN**

Les juridictions pénales de droit commun sont au nombre de **3** :

- **Tribunaux de police** qui relèvent des **tribunaux de proximité** et **jugent des contraventions**. La personne mise en cause devant un tribunal de police s'appelle un **contrevenant**.
- **Tribunaux correctionnels** qui relèvent des **tribunaux judiciaires**, la personne mise en cause est appelée le **prévenu**.
- **Les Cours d'assises** qui ont pour objet de **juger des crimes**, la personne mise en cause porte le nom d'**accusé**.

La loi du 23 mars 2019 a, en plus créé les **Cours criminelles départementales** dans le but de désengorger les cours d'assises.

PARAGRAPHE 1 : LES TRIBUNAUX DE POLICE

Lorsque le tribunal de proximité juge en matière répressive, il prend le nom de tribunal de police. Le tribunal de police est chargé de **juger des contraventions**, c'est-à-dire les **infractions les moins graves**. C'est l'article 521 du Code de procédure pénale ; les contraventions sont les infractions les moins graves et sont susvisées en 5 classes : la première étant la moins grave et la 5^e étant la plus grave.

En principe, le tribunal de police a tendance à se concentrer sur les infractions les plus graves, celles de 5^e classe. Les autres classes de contraventions (1^e à 4^e) peuvent faire l'objet d'une **procédure simplifiée d'amende forfaitaire**. Dans une telle hypothèse, le contrevenant est invité à payer une **amende minorée, sans passer par le tribunal**. Néanmoins, il lui reste toujours la possibilité de contester une telle amende devant le tribunal de police. Le tribunal territorialement compétent est celui dans le **ressort** duquel a été **commise la contravention** ou, celui dans le ressort duquel **réside le prévenu** : c'est l'article 522 du Code de procédure pénal.

Devant le tribunal de police, l'accusation est assurée par le **procureur de la République**, bien souvent il va requérir pour les contraventions de 5^e classe et, de manière moins récurrente, il peut le faire pour les contraventions de classe inférieure. En son **absence**, c'est le **commissaire de police** qui représente le ministère public.

PARAGRAPHE 2 : LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

Au sein des tribunaux correctionnels, il convient de distinguer entre la **formation de jugement** et les **juges spécialisés**, notamment dans l'instruction de l'affaire.

A. LA FORMATION DU JUGEMENT DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

S'agissant d'abord de la formation de jugement, elle se compose bien souvent du **président et de 2 assesseurs** qui **statuent alternativement en matière civile et en matière pénale**. Il n'y a donc pas de formation pénale permanentes. Dans les **tribunaux plus importants**, il existe des formations pénales permanentes que l'on appelle les **chambres correctionnelles**. Le tribunal compétent est soit **le lieu de commission du délit**, soit le tribunal du **lieu d'arrestation** ou encore, le tribunal du ressort du **lieu de résidence** du prévenu.

En principe, le tribunal correctionnel statue de façon **collégiale : à 3 juges**. Néanmoins, bien souvent la collégialité a été remise en cause et ainsi, désormais, il existe une **liste d'infractions** posée à l'article 398-1 du code de procédure pénale qui prévoit que, pour les infractions les moins graves figurant dans cette liste, on peut recourir à un **juge unique**. La liste de ces délits n'a cessé de croître : il s'agit de **délits routiers**, des **outrages**, des **délits de chasses** etc. Tous ces délits sont punis au maximum par **5 ans d'emprisonnement**. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les auteurs de délits mais, sa compétence est également étendue pour juger des **contraventions comex** (par exemple, si lors d'un délit de fuite on commet un excès de vitesse et brule un feu : tout est regroupé) **au délit principal**. Ceci est en vertu de la règle suivant laquelle **l'accessoire suit le principal**. Sont qualifiés de délits les **infractions** qui sont punies d'au moins **2 mois d'emprisonnement** ou d'une **amende égale ou supérieure à 3750€**.

B. LE MINISTERE PUBLIC

Le ministère public est représenté par le **procureur de la République** ainsi que **ses substituts**. Les procureurs **assurent la défense de la société** et, ont plus largement pour charge de

représenter les **intérêts de la société**. Les magistrats du ministère public interviennent principalement en matière **pénale** et, on la **charge de l'accusation**. Ils sont considérés comme une véritable partie au procès pénal, ils ne sont pas les juges ; c'est pourquoi ils peuvent notamment faire appel lorsque le mis en cause est épargné après le jugement. Lorsque le prévenu est mis hors de cause devant le tribunal correctionnel, on parle de **relaxe**. L'accusé est mis hors de cause devant la Cour d'assises, on parle d'**acquittement**.

Le travail des membres ministère public se situe surtout en **amont du procès** et même en **amont de l'audience** car, c'est le procureur de la République qui **reçoit les plaintes et les procès-verbaux d'infractions**. C'est également sous son autorité que sont conduites les enquêtes préliminaires à l'issue desquelles, il décidera ou non d'engager des poursuites. Il a aussi la charge des **procédures intermédiaires** comme la composition pénale ou encore le rappel à la loi.

C. LE JUGE D'INSTRUCTION

Le juge d'instruction est un juge qui, en matière pénale est chargée de **diriger l'enquête** lorsqu'il y a lieu de procéder à une **enquête beaucoup plus approfondie** qu'une simple enquête préliminaire. Cette enquête approfondie est appelée **information judiciaire**. C'est ce qui suit l'enquête préliminaire. Le juge d'instruction est un magistrat du siège, il est donc **inamovible et irrévocable**. Il est nommé pour **3 ans renouvelables par décrets du résident de la République**. Il a pour mission de **diriger l'enquête objectivement**, c'est-à-dire, **instruire à charge et à décharge**, c'est l'article 41 du code de procédure pénale. Il s'appuie sur les officiers de police judiciaire pour son enquête. Il peut par exemple procéder à des auditions ou à des interrogatoires de témoins. Il possède de nombreuses prérogatives : il peut procéder à des perquisitions, opérer à des saisies et, se transporter sur les lieux. Il peut même solliciter le concours de la force publique pour procéder de à des auditions avec des mandats.

A l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction va prendre une **ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel** s'il estime qu'il existe, sur la personne mise en examen, des « *indices graves et concordants rendant vraisemblables la commission de l'infraction* » c'est l'article 80-1 du code de procédure pénale. S'il n'existe pas de tels indices, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Son ordonnance de renvoi ou non-lieu est susceptible d'appel devant un organe particulier : la **chambre de l'instruction de la Cour d'appel**.

D. LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Cette fonction a été créée par la loi du 15 juin 2000, la loi Fauchon, depuis, il faut savoir que le **juge d'instruction n'a plus le pouvoir de prononcer une mise en détention provisoire**. Cette compétence est **transférée aux juges des libertés et de la détention**.

Cette fonction est très importante dans un tribunal, c'est pourquoi elle est confiée au **vice-président du tribunal judiciaire, désigné par le président**. Chaque tribunal judiciaire

départemental comporte au moins un JLD. Le JLD **statue sur la mise en détention**, il doit être saisi à cette fin par une **ordonnance motivée du juge d'instruction**, aux vues des réquisitions du procureur de la République. Il se prononce après une **audience contradictoire**. L'ordonnance du JLD est **susceptible d'un appel** devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel. Cet appel peut être exercé par le **mis en détention** ou encore, par le **procureur** de la République. Le JLD dispose également d'autres prérogatives et, notamment, il peut permettre la **prolongation de la garde à vue au-delà de 48h** ou, il peut permettre **l'interception des communications téléphoniques**.

PARAGRAPHE 3 : LES COURS CRIMINELLES DEPARTEMENTALES

C'est l'une des principales mesures de la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice. Il y a eu la création de **7 cours criminelles départementales** et, l'expérience est prévue pour durer 3 ans, jusqu'en 2022 et pourra être prolongée. Les cours criminelles départementales sont compétentes pour les crimes les moins graves, commis par des **personnes majeurs, punies de 20 ans de réclusion maximum**. Il s'agit principalement des **crimes sexuels**, des **vols à main armée**. Les crimes en état de récidives sont exclus. L'objectif est de s'engorger les cours d'assises et, de permettre un jugement plus rapide des crimes. Il s'agit aussi de limiter à l'avenir les condamnations de la France par la Cour Européenne des droits de l'Homme pour non-respect des **exigences du délai raisonnable** telles que posées à l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH. Il s'agit aussi de **limiter** une pratique du législateur que l'on appelle la **correctionnalisation**, qui vise à **requalifier certains crimes en délits** pour le soustraire à la compétence non **plus de la Cour d'assises mais du tribunal correctionnel**. Par exemple, un viol sera requalifié en agression sexuelle par la correctionnalisation.

PARAGRAPHE 4 : LES COURS D'ASSISES

La Cour d'assises est la juridiction de droit commun chargée de **juger les crimes**. Son originalité principale tient à sa composition ainsi qu'à son organisation.

A. LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES

Au sein des tribunal criminel mis en place à la **Révolution**, on trouvait un **jury criminel composé de citoyen**. Ces tribunaux criminels ont pris le nom de **Cour d'assises en 1810** mais, **jusqu'en 1942, le jury populaire décide seul de la culpabilité** et les magistrats professionnels fixent le quantum de la peine. La loi du 25 novembre 1941 met un terme à cette anomalie et, attribue à toute la Cour d'assises, **jurys de citoyens et magistrats professionnels, le soin de se prononcer de concert (ensemble), sur la culpabilité et la peine**. Par cette loi, le nombre de **jurés** est réduit de **12 à 9** et, il est abaissé à **6** à partir de 2012 par la loi du 10 août 2011. La Cour d'assises comprend 3 magistrats professionnels : le président qui est un magistrat issu de la Cour d'appel et, 2 assesseurs qui peuvent être des magistrats issus de la Cour d'appel ou du tribunal judiciaire départemental. Le jury est composé de simples citoyens de 23 ans révolus. Il existe certaines incompatibilités posées par l'article 257 du code de procédure pénales, notamment pour les parlementaires, les magistrats ou les fonctionnaires de police.

Les jurés sont tirés au sort à partir des listes électorales. Lors du tirage au sort pour chaque affaire, la défense peut récuser 4 noms et, le ministère public peut en récuser 3. Le juré reçoit une indemnité journalière de comparution et, une indemnité de perte de salaire qui est au moins équivalente au taux horaires du smic.

Le ministère public ou le parquet, est représenté par l'avocat général toutes les fois où la Cour d'assises siège au sein de la Cour d'appel.

B. LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES

La Cour d'assises était traditionnellement la seule juridiction compétente pour juger des crimes qui se définissent comme les infractions punies d'une peine de **réclusion supérieure à 10 ans**, à savoir les assassinats (préméditation) ou meurtres. Elle partage désormais ses compétences avec les cours criminelles départementales et se charge désormais de juger les crimes les plus graves, c'est-à-dire ceux punis d'une peine de réclusion supérieure à 20 ans.

Par exception, elle n'est pas compétente pour juger des crimes commis par des mineurs car, dans une telle hypothèse, est compétente la Cour d'assises des mineurs. Elle n'est pas compétente pour les crimes de terrorisme non plus car, c'est la Cour d'assises spéciales qui est compétente dans une telle hypothèse. Elle est compétente pour juger des contraventions comex aux crimes principal réalisé.

S'agissant de sa compétence territoriale, c'est la Cour du lieu de commission du crime ou du lieu de l'arrestation de l'accusé ou du lieu du domicile, qui est compétente.

C. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR D'ASSISES

Il existe 1 Cour d'assises par département, elle siège dans les locaux de la Cour d'appel ou dans les locaux du tribunal judiciaire. La Cour d'assises est saisie par le juge d'instruction aux moyens d'une ordonnance, non pas de mise en examen, mais d'accusation. Les Cour d'assises ne sont pas permanentes, elles siègent par sessions. Les sessions ordinaires sont d'une durée de 15 jours par trimestre et, il peut y avoir des sessions extraordinaires qui viennent s'ajouter.

Les jurés n'ont pas accès à l'intégralité du dossier mais, ils ont seulement accès à l'ordonnance de mise en accusation. La Cour et le jury statuent par une délibération commune sur la culpabilité et sur la peine. Une majorité qualifiée est exigée pour se prononcer sur la culpabilité donc une condamnation, c'est-à-dire au moins 6 voix sur 9.

Les arrêts de la Cour d'assises sont susceptibles d'appel, c'est alors une autre Cour d'assises désignée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui rejugera l'affaire. Cette nouvelle Cour d'assises est composée cette fois-ci de 3 jurés supplémentaires. La majorité qualifiée exigée sera alors de 8 voix sur 12.